

## 契約解釋與任意規定<sup>\*</sup>

### —— 比較法與案例研究

王文宇<sup>\*\*</sup>

#### 摘 要

契約解釋是契約法中無所不在的現象。在實務上，由於當事人疏未注意或有意省略，契約往往藏有漏洞，如何填補這些漏洞即成為解釋契約時的重要課題。在大陸法系國家，民法提供了任意規定用以補充或解釋當事人意思，然而，任意規定既為立法者預設的典型權利義務分配方式，若當事人間的利益狀態過於偏離立法者預設的情形時，適用任意規定反倒無法得到最恰當的結論。據此，本文透過案例分析和比較法研究，探討契約解釋和任意規定之間的關係。本文發現，在某些案例中，臺灣法院為了適用法律，過於倉促地為契約定性，或僵化地透過類推適用把任意規定套用在契約上，而未探究契約的本質或締約目的。本文乃提出契約解釋的三步驟如下：一是區辨契約法的強制與任意規定，二是釐清契約解釋與任意規定的關係，三是慎選填補契約漏洞的方式，而非一概機械性地套用任意規定。

關鍵詞：契約解釋、任意規定、強行規定、比較法研究、契約自由、契約漏洞、類推適用。

\* 本文簡體版曾以〈合同解釋三部曲——比較法觀點〉為題，刊載於中國法律評論，2016年第1期，頁60-89。

責任校對：徐寧、呂佳霖。

\*\* 國立臺灣大學法律學院教授。

穩定網址：<http://publication.iias.sinica.edu.tw/41907171.pdf>。



## 目 次

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 壹、前言             | 伍、契約（法）解釋第三部曲      |
| 貳、無所不在的契約解釋      | ——慎選漏洞填補的方式        |
| 一、契約不完整性與契約法任意規定 | 一、契約漏洞的填補——通說      |
| 二、法律解釋與契約解釋      | 二、案例研究——一則保證契約判決   |
| 三、契約法解釋與契約解釋     | 三、比較法觀點            |
| 參、契約（法）解釋第一部曲    | 陸、差別待遇？商事與非典型契約的解釋 |
| ——區辨強行規定或任意規定    | 一、民事與商事契約的雙元發展     |
| 一、強行規定的界線——通說    | 二、解釋民商事契約的差異       |
| 二、案例研究——一則工程契約判決 | 柒、相關概念的釐清          |
| 三、比較法觀點          | 一、請求權基礎            |
| 肆、契約（法）解釋第二部曲    | 二、誠信原則             |
| ——釐清契約解釋與任意規定    | 三、契約定性與類推適用        |
| 一、契約解釋與任意規定——通說  | 捌、兩岸契約解釋法制的比較      |
| 二、案例研究——一則經銷契約判決 | 一、臺灣法制的摘要          |
| 三、契約解釋——比較法觀點    | 二、中國大陸法制的簡評        |
|                  | 玖、結語               |

## 壹、前言

「契約」（亦稱合同）是人際互動與市場運作的基礎，以「契約法」作為確保履行的憑藉，兩者關係密切。現代私法尊重契約自由，例如歐洲「共同參考架構草案」（Draft Common Frame of Reference, DCFR）開宗明義規定：「除受強行規定制約，當事人得

自由締結契約並決定其內容。<sup>1</sup>」至於契約應納入何種強行規定的制約？則有疑問；其次，契約法重視當事人自治，然而當法院面對契約爭議，應如何適用契約法解釋契約？亦非易事；再者如當事人契約就相關爭點並無約定，法官針對如何填補漏洞？有時煞費苦心。尤其大陸法系民法典多設定契約類型與任意規定，此舉雖可減省當事人締約成本，但應如何選擇適用方符合當事人自治精神？亦宜審慎考量。追根究柢，欲釐清契約與契約法之關係，涉及契約解釋的基本問題。

著名德國契約法學者Claus-Wilhelm Canaris與Hans Christoph Grigoleit曾言：「契約解釋是契約法上無所不在的現象。<sup>2</sup>」儘管如此，海峽兩岸傳統契約法教育多重視法條釋義而輕忽契約解釋，影響所及，法學家往往視契約解釋為法律解釋或契約法解釋的一環，鮮少專就它進行整體性研究<sup>3</sup>。然而現代市場中，五花八門的契約類型屢見不鮮，尤其複雜多變的商事糾紛更層出不窮，例如近年爭議不休的收益權信託案件，就是典型案例<sup>4</sup>。事實上，契約解釋學博大精深，不但涉及公平與正義理念，而且牽動政策及效率考量，突顯多元的取捨與抉擇可能性。舉例言之，德國與英國均為經濟發達與法制完備國家，但面對疑難契約時，卻採取相當不同的解釋規則。是故我們宜回歸基本面，從比較法的視角探索契約（法）解釋此一歷久彌新的議題。

---

1 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline Edition 2009, Art. II-1:102, [http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr\\_outline\\_edition\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf).

2 Claus-Wilhelm Canaris & Hans Christoph Grigoleit, *Interpretation of Contracts* 1 (Jan. 15, 2010), <http://ssrn.com/abstract=1537169>.

3 參見韓世遠，民事法律行為解釋的立法問題，收於：民法的解釋論與立法論，頁311-322（2015年）。

4 參見上海市高級人民法院2013年滬高民五商終字第11號民事判決書。本案涉及契約定性（金融借款契約糾紛還是營業信託糾紛）、某投資開發公司是否違約及責任認定、某股份有限公司可否實現抵押權等爭點。

我們如仔細推敲，疑難契約的解釋其實涉及三個基本步驟與問題，第一，契約法針對疑難契約，是否設有強行規定？此時我們須釐清相關契約法規定是強行規定或是任意規定？方能做出判斷。第二，如以上答案為否定，接著我們應回歸系爭契約本身，採取適當解釋方法決定當事人之真實（或合理）意思，以做出判決；此時宜考量契約法是否有任意規定可資參考援用？應注意者，是否應引用任意規定有時不易判斷，稍有不慎可能使任意規定變成「黏稠的任意規定」（sticky defaults）<sup>5</sup>，產生「寧可誤引條文、迴避適切解釋」的不當後果。第三，某些契約可能未針對系爭事項做出明文約定，就涉及如何填補契約漏洞的問題，此時除非法官宣告契約不成立，即須透過適當方法去填補契約漏洞。以此觀之，上述三步驟好似契約（法）解釋的三部曲，允宜循序漸進、逐一考量<sup>6</sup>。

正確的契約解釋，係健全法制與發展經濟的基石。有鑑於此，本文從比較法觀點，探討契約（法）的解釋問題，第貳部分首先釐清契約法解釋與契約解釋的關係；接著三個部分探討上述解釋的三個步驟，第參部分（第一部曲）嘗試區辨強行規定與任意規定的分際，第肆部分（第二部曲）討論契約解釋與任意規定間如何取捨；第伍部分（第三部曲）探討當契約出現漏洞時，如何選擇漏洞填補的方式。現代社會中民事契約與商事契約呈現雙元發展，因此本文第陸部分扼要說明民商事契約在解釋上的差異；第柒部分檢討與契約（法）解釋相關的幾項法律概念，包括請求權基礎、誠信原則與類比推理等。

本文參酌美國、英國與德國契約法權威學者的論著，由於臺灣

---

5 有關「黏稠的任意規定」的討論，請參考Ian Ayres, *Regulating Opt-Out: An Economic Theory of Altering Rules*, 121 YALE L.J. 2032, 2045 (2012).

6 如後所論，並非所有疑難契約均涉及這些基本問題，而且這些問題的界線並非都很明確（例如契約是否有漏洞本身就涉及解釋），但我們唯有依循這三個步驟進行，才不致迷失於契約法與契約解釋的五里霧中。

屬大陸法系成員，契約法發展也受到英美契約法的影響，因此本文特別討論德國與英國契約解釋的差異，希冀作為比較與詮釋的參考。同時，本文亦援引具代表性的法院判決並加以評析，以期能更加具體之闡明契約解釋之影響和重要性<sup>7</sup>。此外，觀察中國大陸之契約解釋發展，頗有可供參考之處，本文第捌部分先摘要臺灣法制，再簡要評論中國大陸法制，以供讀者參考。此舉僅能算是兩岸契約法的初步比較，可能流於簡略，宜先敘明。第玖部分為結語。

## 貳、無所不在的契約解釋

### 一、契約不完整性與契約法任意規定

現代契約往往是不完整的，有時即使宣稱一紙契約不需要解釋，本身也是一種解釋。無論口頭或書面形式，無論當事人意思表示合致的內容為何，凡涉及到締約之後的履行，必然就關係著契約的解釋。理想情況下，當然是當事人對契約如何履行的解釋一致，但在更多時候，當事人對相同一份契約，往往會因不同的解釋，而主張歧異的處理方法。契約的締結可能有各式各樣的型態和目的，然而不脫當事人希望藉由契約確保雙方的履行，進而盡可能追求彼此最大的利益。但要設計出能夠達成最大利益，並能妥善地對未來情事的變更做出彈性因應的契約並不容易。

契約法的制定，彰顯了立法者對於契約以及不同契約型態之預設。然而現代契約，尤其是商事契約，與立法者當初所預設之契約型態恐已大不相同，現代契約由於分工、科技技術等的發展，變得

---

<sup>7</sup> 本文某些論點與案例討論，曾出現於王文字，商事契約的解釋——模擬推理與經濟分析，中外法學，2014年第5期，頁1270-1289（2014年）。為閱讀方便並載於此文中，敬請一併參考。

更加多元，不論是契約型態、當事人間權利義務關係等等，都愈加複雜和富於變化，而在許多為了長期關係而生的契約中，也面臨著更高的各種變動風險，長期契約中該如何因應情事變更，做出妥善的契約解釋，使契約的履行合乎當事人利益以及最大經濟效益，亦成為現代契約重要的特點。

學者Robert E. Scott曾整理出在理想狀態下，締約雙方當事人可以根據成本的考量，在能夠負擔成本時，選擇締結較完整、全面的複雜契約（*complex contract*），盡可能將雙方權利義務完整規範、將未來所有可能情形納入契約中，並排除未來重新協商的可能。而在成本無法負擔，例如未來的不確定性過高時，選擇締結未將所有未來情形訂明的簡要契約（*simple contract*），簡要契約可能包含確定的、剛性的契約條文或者模糊的、軟性的契約條文，若包含確定的契約條文，則締約雙方可能會預期未來能夠重啟談判；而包含模糊的標準（*standards*）時，則需要例如第三方的調整、仲裁機制<sup>8</sup>。在現行法律及其他條件下，理想狀態中完全的複雜、簡要契約雖然無法達成，但以此向度可一窺現代契約之特性。

其中較為簡單、模糊，保留較多彈性的契約又稱為不完整契約（*incomplete contract*），意指締約當事人於締結契約時不將契約履行期內所有可能發生的情形及其衍生出的法律效果訂明，而通常會存在漏洞或者因應未來情事而調整、再協商的彈性。不完整契約的存在，並不總是代表當事人的怠惰或者疏忽，更有可能是因為締結完整契約的成本過高，且準確預測未來過於困難，而使得當事人選擇締結不完整契約。

導致契約不完整的原因主要有二，一是有限理性，即人因其理性及思慮之限制，無法對未來事件及外在環境之變化做完全準確之

---

8 Robert E. Scott, *The Law and Economics of Incomplete Contracts*, 2 ANN. REV. L. & SOC. SCI. 279, 294 (2006).

預測；二則是考量預測未來並將所有可能情形及其導致之權利義務關係皆訂入契約之成本可能過高。在撰寫契約時，當事人可能於事前起草契約時，必須預測可能發生的情事並設想情事發生時之權利義務關係而負擔前端成本（front-end cost），而於契約約定的情事發生時，必須付出監控雙方履約情形、以及透過訴訟確保履行的後端成本（back-end cost）<sup>9</sup>，這些成本的存在導致契約當事人無法締結內容明確、對所有可能情形皆有所考量，而使得法院能夠簡單的要求當事人按照契約約定履行的完整契約。交易成本可能造成兩種不完整契約的類型：（一）未考量未來所有可能情狀發生時當事人間之權利義務關係；（二）就算對未來的可能情狀皆約定相對應之當事人關係，亦有可能因資訊的缺乏而造成契約無法達到最有效率、最（於經濟學上）理想的權利義務狀態<sup>10</sup>。

而對於選擇訂定契約的當事人而言，確保約定事項的履行無疑是其終極目標。契約之解釋、法律效果等等，受到契約法一定程度的規範和介入，然而契約與契約法之範疇並非全然重疊，契約之履行也並非全然倚賴契約法的強制力或執行力。尤其是在長期契約與簡要契約中，契約的履行除了法律的介入外，亦需要非正式的機制如商譽、交易習慣、互利的常規等等來維繫契約的履行。學者 Robert E. Scott 即指出，不完整契約理論給予我們重要的啟示之一即是法律的強制力並非確保合作雙方福祉最大化的唯一機制，尤其在簡要契約中其扮演的角色相當的受限<sup>11</sup>。於此，契約解釋與其他履行機制應扮演更重要的角色。

然而此並不意味著法律在契約的履行上失去其作用，而毋寧應將其視作對於分析不完整契約時所應考量的其他履行機制的提醒。

---

9 ROBERT E. SCOTT & GEORGE G. TRIANTIS, FOUNDATIONS OF COMMERCIAL LAW 23 (2010).

10 *Id.* at 23-24.

11 Scott, *supra* note 8, at 279.

事實上，契約法在契約中仍扮演著一定的角色，尤其在契約法中仍然存在著強行規定的存在，而於部分情形當事人也仰賴契約法的強制力，以及利用任意規定降低交易成本。但需注意，於契約法中，強行規定仍為少數，基於向來支配契約法的當事人自治、契約自由的法理，契約法中當事人得以明文排除的任意規定毋寧才是構成契約法的主體。

任意規定之目的，一般認為乃係為了節省交易成本、提升契約的完整度並以此提升契約的效率<sup>12</sup>，所以其乃係設計來反映典型的契約及契約當事人的目的<sup>13、14</sup>。透過訂定任意規定，立法者預設了大多數狀況、及相同狀況下當事人可能選擇的契約內容，有助於減低前述當事人需預測、規劃未來所造成的前端成本（front-end cost），增加契約的效率。同時，也為無法負擔此前端成本的締約當事人預設了權利義務關係，提升契約的完整度<sup>15</sup>。而任意規定又可分為兩類，及規則（rules）及標準（standards），其中規則係以任意規定事前決定該行為在法律上是被允許的，對於法院而言，其面

---

12 SCOTT & TRIANTIS, *supra* note 9, at 25.

13 See Hans Christoph Grigoleit, *Mandatory Law: Fundamental Principles* 1 (Oct. 29, 2011), <http://ssrn.com/abstract=1950670>.

14 除此之外，有些學者主張任意規定亦有所謂的「懲罰性任意規定」（penalty default），（又稱為「強制資訊揭露規定」（information-forcing default），不同於一般任意規定，此通常發生於當事人雙方資訊不對等之時，其提升效率之方法為提供誘因使一方願意提供資訊給另一方，而於此種資訊不對等的情形懲罰性任意規定較之一般預設概然律較高之典型契約及其權利義務關係之任意規定，更能有效提升交易效率，同時相對於一般任意規定預設多數情形的立場，其乃係為了少數情形、少數人之利益而制定。然而亦有學者主張一般任意規定亦有強制資訊揭露之功能，且法院在判決時向來認為自己是依照多數人之利益、多數情形而為判決，因此不應存在以此為區分標準之懲罰性任意規定，若任意規定似乎違反多數情形或多數人之利益，極有可能只是立法者誤解了多數情形及多數人之利益。而相對於懲罰性任意規定，一般任意規定又被稱為「多數任意規定」（majoritarian default rule），see Eric A. Posner, *There Are No Penalty Default Rules in Contract Law* 1 (U. Chi. L. & Econ. Olin Working Paper No. 237, 2005), <http://ssrn.com/abstract=690403>.

15 SCOTT & TRIANTIS, *supra* note 9, at 25.



對規定時僅剩餘事實的判斷空間；而標準則給予了法院在事實認定及法律解釋上的空間<sup>16</sup>。亦即，規則指的是法律事前即已訂明禁止的事項及內容；而標準則尚仰賴事後的判斷。通常對於發生之概然律較高、變化較低的情事，規則較常被使用，而對於行為人而言，因其較易於理解和預測，了解規則的成本也較低。但是無可避免的是制定規則的立法成本也較高，因其必須詳細的、盡可能地去預測可能的情形。而相對的標準則會出現在發生之概然律較低、事件變化大的情形，交由法院或主管機關等解釋。

在大陸法系國家，任意規定主要存在於由立法者所制定的成文法，但亦有由法院以判例所形成。而於英、美等普通法國家，雖然也有專為交易上典型的契約類型所發展出來的任意規定（*terms implied in law*），但由於立法制定者較少，其中任意規定主要仍是由法院透過判例所形成。

## 二、法律解釋與契約解釋

在討論契約解釋前，必須先釐清法律解釋、契約法解釋與契約解釋之間之關係，此三者可謂環環相扣，因此三者概念之分野一直係學理上的模糊地帶。然而，契約解釋畢竟與法律解釋及契約法解釋本質上有所不同，是故，對此間關係之正本清源，是在辨析契約解釋操作方法時，必要的前提。

所謂法律解釋，最直接的意義即為對法律規定涵義作說明，而這樣的說明必須考量法條的文義、制定背景、在法典系統中的定位乃至立法目的來詮釋，其影響的乃是人們應如何對法律規範為遵循，尤其是針對所謂不確定法律概念之規定，必須透過法律解釋的實踐，始能對人民的行為予以合法或非法之評價。詳言之，法律解釋通常與具體事實密切相關，即必有一待法律評價的事實存在，才

---

<sup>16</sup> *Id.*

有運用法律解釋來評判一事件合法或非法之意義，正因有此評判合法與否之內涵，故法律解釋的運用可謂是一種價值判斷、價值選擇的過程。而於此處價值判斷的作出，基於法安定性的要求，應務求朝向建構普世性的法律解釋標準而努力。

至於契約解釋，則與法律解釋和契約法解釋有較大的差別。三者本質上差異處在契約解釋並不似法律解釋係對一般性法律條文之涵義闡析；而是本於當事人合意所形成的契約內容，解釋契約上法律關係應如何受履行。因契約解釋的對象是契約本身，而契約的形成是緣於當事人做出法律行為所包含的意思表示合致，故契約解釋的重心，毋寧可謂是對當事人法律行為的解釋。法律行為解釋爭議主要涉及之點，為表示及受領表示的雙方當事人，對表示的意旨及理解不同。因而爭論標準的意義為何，原則上應取決於表示者的意指，假使對受領者而言，該意旨已清楚顯示於表示之中的話，受領者於此也須盡力探求表意者的意旨，必要時更應進一步詢問。

知名德國民法學者Karl Larenz主張，解釋法律行為時（特別是契約），主要涉及的問題是：為表示及受領表示的雙方當事人對表示的意指及理解不同，因而爭論的意義為何。原則上應取決於表示者的意指，假使「對受領者而言」該意指已清楚顯示於表示之中的話。反之，在解釋法律時，雙方當事人（制定規範者及受規範者）的理解及理解可能性如何，並不重要，其重要的係法律的前後脈絡關係、目的及歷史上的立法者之意向，背後並隱含著創造正當規整的立法企圖、法律理性的原則、相同事務應做相同處理及避免價值矛盾等<sup>17</sup>。如此見解，確實係掌握了契約解釋與法律解釋區辨的精髓。綜合以上關於法律解釋、契約法解釋與契約解釋之簡析，應可論其彼此間的差異，至少存在於解釋對象、解釋目的、解釋途徑層面上之不同。法律解釋與契約法解釋皆為對法律條文內涵為解釋，

---

<sup>17</sup> 參見Karl Larenz著，陳愛娥譯，法學方法論，頁287（2008年）。

目的都在於如何以適當標準評價具體事件之法律適用，只是後者在為評價時更注重契約法「契約自治」的核心價值；相對的，契約解釋則重視對雙方意思表示合致而成的契約內涵做解釋，解釋的目的則在於探究在契約關係中，當事人應如何適當的履行權利及義務，來達成契約當事人締約之目的。而在解釋途徑上，法律解釋除了法條文義外，更重視從立法背景、法典體系乃至立法者目的來詮釋，務求評價時客觀且具法安定性的基準；契約解釋則是比起對約定文義的理解，更重視當事人在契約當中所欲實現的締約目標，相對於法律解釋傾向追求普世性基準，契約解釋更重在具體個案上當事人在受私法自治保障下，如何讓雙方能皆大歡喜實現自身欲追求價值。

### 三、契約法解釋與契約解釋

再者所謂的契約法解釋，本質上實亦屬法律解釋，只是其範圍較為限縮，專指法律體系中契約法領域之法律解釋。承前述，法律解釋是一種價值判斷過程，故在契約法解釋，應當尊重契約法等私法關係上「當事人自治」、「契約自由」之核心價值。在大陸法系成員中，往往立有契約法的專法（如中國大陸《合同法》），或將之編為民法中專章（如臺灣的民法債編第二章：各種之債），而在制定內容上，往往係對各式人民生活中常見契約，預設規範當事人間基本權利義務關係之「任意規定」，而當遇契約漏洞出現時，任意規定即可發揮填補之作用，彌補雙方約定未盡之處。結合個案事實與契約法解釋時，衍生的問題主在於當事人所訂定的契約，是否應以任意規定預設的權義關係優先操作。傳統常見典型有名契約上，引入任意規定處理或爭議較小，但對當今五花八門的商事契約而言即為重大疑義，如何秉於契約法核心價值來對解釋契約法規在個案上的運用，正為契約法解釋的中心課題，也是其與一般法律解釋不同的特色之處。

## 參、契約（法）解釋第一部曲——區辨強行規定或任意規定

### 一、強行規定的界線——通說

法律依照當事人是否得以合意排除其適用，分為任意規定與強行規定。顧名思義，強行規定當事人不得以其意思排除適用，至於任意規定，其功能傳統上主要認為乃在於補充當事人之意思，於當事人未明示排除時仍具強行性而應適用之<sup>18</sup>，一般又將任意規定分為補充規定及解釋規定，前者乃於當事人無特別意思表示時，補充其意思之法律規定，後者乃為於當事人意思不明時，用以解釋其意思表示之法規。契約法中為實踐私法自治原則，應係以任意規定為主<sup>19、20</sup>。而如前所述，除了補充當事人意思之外，任意規定就法經濟學之角度而言，亦有提升交易效率、契約完整度的目的，其乃係立法者針對若干交易上經常發生之典型契約類型，就其認為有待規範事項，將自己置身於契約當事人的立場，斟酌契約目的與當事人利益狀態、基於公平利益之衡量，就其認為凡一般理性當事人應會為如此約定之事項，訂為條文，於契約有漏洞時適用該條文，以節省當事人預測未來、規劃權利義務關係之成本。

至於強行規定同為立法者預先衡量契約當事人利益狀態，所訂下符合社會公平正義的規則。其不問當事人意思如何，一律適用成為契約內容。討論上一般將強行規定區分為強制規定與禁止規定，禁止規定中又再區分為取締規定與效力規定。當事人約定的內容，若牴觸禁止規定中的效力規定，至少牴觸部分契約內容不發生法律規範拘束力；若僅違反取締規定，則僅係主管機關得對違反者加以

---

18 參見王澤鑑，民法總則，增訂版，頁52（2001年）。

19 同前註。

20 Grigoleit, *supra* note 13, at 1.

制裁，以禁遏其行為，並不否認其行為之私法上效力。強制規定則指禁止規定以外的強行規定，不問當事人意思如何，強行規範當事人間的契約關係。是故，強行規定在契約內容形成所扮演的角色，主要顯現在當事人根本未有約定時。如契約當事人雖未約定強行規定之內容，本於其法律效力之展開，雖無關契約當事人意思仍成為契約的內容。

強行規定由於限制了個人的意思自主並破壞私法自治的原則，應為契約法中的例外，立法應受到嚴格限縮，並須有較強的論述和立法理由支持。這也因為雙方當事人通常較之於立法者擁有更多的資訊得以評估如何的法律關係和安排對自身較有利，同時，任何偏離當事人合意或目的的規定都會造成當事人的成本，例如當事人可能需要花費更多成本去尋找其他方式達成原先的目的，而法律的不確定性亦會造成當事人額外的成本。另外，於介入私法自治領域時，一般較傾向於使用提供誘因的方式而非直接為當事人做權利義務關係的分配，此也使強行規定需要更強烈的論理和立法理由支持<sup>21</sup>。

除了上述以效力作區分外，強行規定依據其規範目的之不同，亦可能有三種型態<sup>22</sup>，一為透過強行規定貫徹社會的基礎功能和價值，例如維護人格尊嚴、保障社會安全、維繫家庭功能，以及如增進市場競爭效率等等；二則為關於相關信賴之保護，藉此促進交易安全和商業效率。例如對於可能受雙方協議影響之第三人，其信賴在某些例子下即有保護之必要，物權法定主義即寓有此意涵。最後，亦是私法近期最顯著之發展趨勢，即為對交易中較弱勢一方之保障；例如租賃契約中之承租人、勞動法領域中之受僱人以及消費者保護法中之消費者。而某些以消除歧視為目標之強行規定亦屬於

---

<sup>21</sup> *Id.* at 4.

<sup>22</sup> *Id.* at 2-3.

此領域，例如性別、身心障礙者等等。此類型之強行規定乃係由於立法者預期契約中較弱勢的一方無法有效地與較強勢的一方議約，進而可能導致契約的無效率或者弱勢方無法維護自己的利益。

強行規定與任意規定之效力與目的理論上雖較容易二分，但實務中個別條文究屬任意規定或強行規定，其界限甚難辨明。學者有認「應依其規範目的認定之」<sup>23</sup>，惟所謂規範目的，有時仍然未盡明確，尤其任意規定與強行規定皆由立法者以預設方式制定於法條中，但這些預設規定究竟是作為補充的契約解釋之任意規定，抑或必須被納入契約內容之強行規定，一般並無被立法者清楚的指出，而仰賴學理與實務對其性質的評價。

以臺灣契約法為例，在民法債編第二章第二十四節「保證」一節中，第739條之1條訂有：「本節所規定保證人之權利，除法律另有規定外，不得預先拋棄。」但再觀第746條第1款之規定，保證人得拋棄第745條所賦予之先訴抗辯權，此賦予契約當事人得排除適用法律預設權利義務關係的條文，即明顯表彰先訴抗辯權的存在是一種任意規定。但也有較為曖昧的情況，比方第741條規定：「保證人之負擔，較主債務人為重者，應縮減至主債務之限度。」此係所謂保證契約的「從屬性」規定，但這樣應縮減至主債務之規範，究竟為當事人須逕行採為契約內容之強行規定，還是當事人可合意排除的任意規定，在未經過嚴謹的法理探討前實難以區分。

同樣問題也出現在民法債編第二章第五節租賃一節中，其第434條明文：「租賃物因承租人之重大過失，致失火而毀損、滅失者，承租人對於出租人負損害賠償責任。」承租人僅於有故意或重大過失時始負損害賠償責任，此係減輕承租人責任之例外規定，在此法條僅規範承租人負重大過失責任的情況，若當事人約定「加

---

23 王澤鑑（註18），頁52。

重」承租人注意義務，例如約定承租人只要有抽象輕過失導致失火即應負損害賠償責任，則如此是否有被解釋為違反強行規定之疑慮，即頗值思考。學說多認為此條規定並非強行規定，若當事人間有為加重承租人注意義務為善良管理人注意義務之特約，此特約和公序良俗無涉，應屬有效<sup>24</sup>，實務亦採取同種見解<sup>25</sup>。惟有學者認為將承租人關於租賃物失火責任回復為抽象輕過失，是否符合租賃之社會政策要求即值得重新思考，尤其是在出租人就失火損失尚能利用保險加以分散時<sup>26</sup>。此外，學說與實務並未討論若約定加重承租人之注意義務至無過失責任時該約定是否有效、是否有違反該條立法目的而認為無效之可能？若認為該特約應為無效，則民法第434條究為強行規定或任意規定？似乎無法斷然下定論。

尚有疑問者，於民法總則編及債編通則中，關於終止之規定僅第263條：「第二百五十八條及第二百六十條之規定，於當事人依法律之規定終止契約者準用之。」並無如撤銷般訂有一般性規定。所謂終止，與撤銷相對，乃是向後的發生契約解消之效力，一般咸認有法定終止與意定終止兩種，前者係根據法律規定而使契約一方有終止權自不待言，後者則由當事人協議，可能合意終止亦可能於契約中訂明於一定情況下當事人一方享有約定終止權。傳統上臺灣學者一般認為終止主要適用於繼續性契約，撤銷則主要用於一次性契約。

惟此生疑義之處在於，關於終止之規定是否為強行規定？於法定終止之情形，其立法目的可能係為保護契約中弱勢之一方、亦可能係立法者預期於某情況下該契約已無繼續之必要，以租賃契約為

24 參見史尚寬，債法各論，頁182（1986年）；劉春堂，民法債編通則（一）——契約法總論，增訂版，頁282-283（2011年）。

25 參最高法院98年度台上字第676號民事判決、最高法院89年度台上字第1416號民事判決。

26 參見黃茂榮，債法各論（一），增訂版，頁82-83（2006年）。

例，民法租賃一節訂有許多關於終止權之規定，且不定期租賃契約，雙方當事人依民法第450條第2項：「未定期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於承租人之習慣者，從其習慣。」得隨時終止契約。然此終止權規定，究係強行規定或任意規定？觀民法第424條規定：「租賃物為房屋或其他供居住之處所者，如有瑕疵，危及承租人或其同居人安全或健康時，承租人雖於訂約時已知其瑕疵，或已拋棄其終止契約之權利，仍得終止契約。」於租賃一節，似乎可認為僅於民法第424條規定之情形禁止當事人以合意排除承租人之終止權而為強行規定，其餘情形，雙方則可合意排除他方之終止權。

於僱傭契約之中，則似乎未有如此明確禁止當事人排除終止權之規定。然民法於第489條規定：「當事人之一方，遇有重大事由，其僱傭契約，縱定有期限，仍得於期限屆滿前終止之。」於第488條第2項規定：「僱傭未定期限，亦不能依勞務之性質或目的定其期限者，各當事人得隨時終止契約。但有利於受僱人之習慣者，從其習慣。」又明定概括之終止權，似乎有特別宣示其重要性之意味，然此是否即可將視其為強行規定？似仍曖昧難明。

基此，在在突顯任意規定與強行規定之區分並非易事，判斷立法者預設規定的性質亦不容易。強行規定與任意規定界限之劃分，表彰了法律解釋與契約解釋往往最後會回歸到價值判斷的取捨，於此，即係對當事人自治與社會公平正義精神的取捨。然而，以強行規定介入契約，不予調整之餘地，對當事人產生之影響極大、副作用亦大。於判斷其界限时，仍應把握強行規定作為契約法例外之原則，於將法規解為強行規定時，宜多加審慎。

此外，強行規定界限之意義，展現於另一層面，即若強行規定代表立法者預設之當事人權利義務關係，則法院得否介入、又得以介入至何程度？以上述終止權為例，除關於終止權之條文本身是否



得由當事人合意排除之疑義外，若當事人並未事先約定、其情事又不該當法定終止，且雙方無法達成終止之合意時，法院得否賦予當事人一方終止權而令其得終止契約？若強行規定代表的是立法者於該情形下之所預設之權利義務關係分配，則法院是否有權力干涉此分配即滋生疑義。

此問題尤其發生於臺灣民法債編通則並未有關於契約終止之規定，僅如上所述規定法定終止權應準用關於撤銷之條文，而未如契約之撤銷般於總則訂有一般性規定之情形。此似乎某種程度上反映了立法者於債務不履行之範疇較傾向於撤銷之意向。惟於現代契約較為複雜、多元，商事契約中回復原狀往往尤其困難之情形，此種傾向撤銷之契約解消方式，似乎並不盡如人意。而於此時，若法院欲賦予系爭契約解消之效果，究應從何處著手、有何法理基礎，即有討論之必要。於臺灣契約實務中，法院於處理無名契約時，傾向於盡量以民法中現有的有名契約定性，再類推適用相關的法條來處理。然如此常使得法院之定性與實際契約之樣貌未盡相同，而使得法院囿於法條，無法做出最妥適之裁量判斷。以終止權而言，在較複雜、契約標的之建設亦往往較龐大、難以回復原狀之工程契約，法院常傾向將其定性為承攬與其他定型契約的混合契約，而於欲賦予承攬人解消契約之權利時以類推適用撤銷之方式處理。此固然係因民法承攬一節關於終止之規定僅有民法第511、512兩條<sup>27</sup>，然而這樣的處理方式於並無法總是合乎當事人最佳之利益分配，畢竟工程契約原狀回復不易，價額亦難以計算，當事人若欲選擇終止，必有其考量。除了法院傾向將無名契約切割劃入有名契約之範疇所造成之問題（詳下述），已定性後，於該有名契約中法律未有明文，

---

27 民法第511條：「工作未完成前，定作人得隨時終止契約。但應賠償承攬人因契約終止而生之損害。」、民法第512條第1項：「承攬之工作，以承攬人個人之技能為契約之要素者，如承攬人死亡或非因其過失致不能完成其約定之工作時，其契約為終止。」

甚至，於債編總則未有關於契約終止明文規定之情形，亦即若立法者預設之權利義務關係為撤銷，而無該當法定終止規定之時，法院能否賦予當事人終止契約之權利？於此，應認為法院基於探求當事人真意、尊重當事人私法自治之契約法領域，為求符合當事人利益狀態、做出合乎公平正義及雙方利益最大化之判決，應許其使當事人得終止契約而非類推適用撤銷之規定。此於回復原狀對雙方無意義、原物返還困難之契約中，應係較合理之處理方式。如僱傭契約中即有對雙方之終止權作較概括的約定，或者如由國際統一私法協會（International Institute for the Unification of Private Law, UNIDROIT）所編寫的國際商事契約通則（2010）（UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010），其在契約解消的部分，僅有終止（termination）的規定，且其僅於一次性契約中僅規定一方可選擇返還所受給付並要求對方亦返還所受給付<sup>28</sup>，而非強制其效果，此立法模式，毋寧較合乎私法自治、當事人自主之法理，亦與上述強調於界定強行規定時宜審慎行事，有異曲同工之妙。

## 二、案例研究——一則工程契約判決

「工程」為臺灣實務上大量出現並多有爭議之契約類型。宜先敘明，因臺灣並不似中國大陸契約法上有「工程契約」之明文，通常在契約定性上多以民法債編各論中的「承攬契約」來處理，是故常滋生疑義。此處即舉以一關於自動倉儲系統工程之合約案為例<sup>29</sup>，事實略為被告昭安公司委託原告新系統公司施作自動倉儲系統工程，惟新系統公司依約將鋼料裝船後，昭安公司尚積欠工程款

---

28 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2010 art. 7.3.6: “On termination of a contract to be performed at one time either party may claim restitution of whatever it has supplied under the contract, provided that such party concurrently makes restitution of whatever it has received under the contract.”

29 最高法院96年度台上字第153號民事判決。

三千六百餘萬元未為給付，且未依約配合硬體設備以致鋼架無從進場施作，新系統公司乃在多次催告未獲置理後，向昭安公司主張終止系爭契約。

臺灣實務對工程契約多定性為承攬契約，承攬契約作為一個大分類，確實扮演提供框架的功能，雖工程契約大致符合承攬契約的架構與目的，但仍具有其獨特性，例如工作物價值較高導致的風險、商事契約的性質、特定性投資、定作人拿翹的問題等等，均使其具有與承攬契約不同的規範需求。若逕將承攬契約之任意規定適用於工程契約，則承包商基於承攬人之地位，得依民法第507條來主張行使「契約解除權」。然而，正因臺灣民法507條預設之任意規定賦予的是解除權，其「回復原狀」之法律效果成本顯然過高，有疏未考量工程契約往往具長期關係契約（relational contract）性質。本案判決中雖有使用「接續性契約」一詞，但其意義究竟為何語焉不詳，仍需進一步分析。無論如何，長期關係性契約往往體現「專屬性資產」性質問題，故比起解除權，更宜賦予承包商的毋寧是終止權。任意規定的適用卻僅賦予承包商解除權，導致任意規定與契約經濟目的需求產生落差，既有適用上的不適宜，則契約補解釋的採行毋寧被優先考量。

慮及當事人之利益狀態與工程契約之本質與目的，此契約涉及「專屬性資產」之投資，故含會計學所稱之「沉沒成本」（sunk costs），是以回歸到當事人經濟實質，針對當事人的締約宗旨與商業習慣做出之假設當事人真意，自應認當事人欲解消契約關係時，解釋上賦予當事人的是「終止權」而非「解除權」。事實上，區分解除及終止兩種不同的形成權，也僅是以成套「契約解消方式+法律效果」搭配，供締約者選用以降低交易成本的機制而已，如果任意規定配套之法律適用產生不效率或不符正義的結果時，法院自應尊重私法自治，做出符合當事人經濟邏輯的解釋。

### 三、比較法觀點

在比較法上，私法自治、契約自由之法理被認為是所有自由社會之基礎，且在歐陸的私法體系中長期以來都受到極高的重視和肯認。由此，在私法領域中，強行規定始終作為例外，此現象可上溯自羅馬法，在羅馬法中，對當事人合意的限制主要來自法律的禁止（*leges perfectae*）及道德標準（*contra bonos mores*），然而，此兩種限制並未獲得長足的發展，契約自由仍相當佔上風；此外，衍生出的對契約自由於法定程序上的限制亦多半讓步於當事人間的合意，並在中世紀被大量的廢除。整體而言，在歐陸法尤其德、法等，在其訂立法典之初，及相當尊重當事人的合意及契約自主之法理。而英國亦非常重視當事人間契約的自由，此與其自由貿易市場於19世紀的崛起有關，其認為契約乃係作為當事人間尋求最大化利益之方式，因此法院極不願意介入干涉<sup>30</sup>。

然而在20世紀後，歐陸法中強行規定日漸受到重視，學者Grigoleit指出其主要在四個層面有逐漸偏重強行規定的趨勢，分別為保護弱勢的契約當事人，實踐社會保護功能、規範定型化契約、消費者保護，以及禁止歧視<sup>31</sup>。在英國，政府源於對契約中弱勢或潛在弱勢一方的保護而開始介入契約，例如租賃關係中的承租人，而第二次世界大戰後德國房屋的短缺也使其開始以強行規定的方式介入保護承租人。此外，對於勞工的保護在20世紀的歐陸法及英國法也逐漸形成，包含對薪資、解僱、休假等之保障，及限制以合意排除保障受僱人之條文。此皆係因於契約中處於弱勢的一方可能無法有效率的與對方進行平等的協商以維護自己的利益，基於社會保護的因素使法律介入，這些保護弱勢一方的立法必須透過強行規定禁止雙方合意排除的方式方能達成立法目的，否則強勢方可能運用其力量強迫相對人同意排除，而使立法目的落空。

---

<sup>30</sup> Grigoleit, *supra* note 13, at 5-6.

<sup>31</sup> *Id.* at 6-9.

除此之外，標準化的契約也受到立法者的關切，現代定型化契約中因為相對人在資訊及對契約訂定、議約上的弱勢，使其很難充分了解遑論與企業具體協商契約內容，在德國，企業對企業（business to business, B to B）及企業對消費者（business to consumer, B to C）契約都受到相關法規的規範<sup>32</sup>，英國歷經演變則僅規範B to C契約中非個別磋商條款的部分<sup>33</sup>。而消費者保護與定型化契約部分重疊，但特定範圍於個人消費者對企業的部分，順應著消費者意識的抬頭而漸受重視。而禁止歧視的相關規定亦蘊有社會保護的功能，例如禁止性別歧視等等。

自上述比較法上關於強行規定之發展趨勢，可以發現雖強行規定逐漸受重視，然其發展之領域仍相對受限，而非廣泛全面的取代任意規定。而於個別條文中，是否涉及需要以強行規定介入保護之領域、受保護之當事人是否處於資訊不對稱或議約能力之弱勢，仍不易判斷。於考量時，不妨參考比較法上之標準、介入之理由，及強行規定發展之領域及趨勢，然仍應不忘以契約自由為原則，謹慎辨別該條文是否有其不得不以強行規定介入之理由，方為穩妥。

## 肆、契約（法）解釋第二部曲——釐清契約解釋與任意規定

### 一、契約解釋與任意規定——通說

#### （一）契約解釋之法理與路徑

契約解釋之所以為複雜的議題，肇因於契約態樣的五花八門。在契約自由原則立場下，常見的典型契約諸如買賣、委任固然每天

---

<sup>32</sup> BGB §§ 305-310 (Ger.).

<sup>33</sup> See Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (Eng.).

都在發生，然相同類型契約中因為當事人的不同，相較智慮單純的市井小民與精打細算的企業廠商，契約法自不宜對它們等量齊觀，尤其現代大量興起的B to B契約，其契約解釋複雜程度又較一般契約更高，因商人往往對其交易標的較一般消費者有更高瞭解，其談判能力、風險預估及承受能力更是較大眾有顯著差異，是故其間所締結的契約，往往秉於交易背後的商業考量，而有不同於法條預設任意規定，或是其他相類似案件的契約內容。又當事人雖有合意才會締結契約，但達成合意的範圍仍可能不明確，尤其因契約目的主要是當事人想像所及的未來事物，對於想像所不及的未知將來與不明確風險，顯然無法皆以契約精確的約定。另外，契約解釋與契約使用的文字息息相關，因文字本身常有不明確、不完全、多義等限制，如何適當的理解契約上的用字遣詞亦是困難所在，縱摒去抽象的交易成本概念不論，再怎麼思慮詳盡字斟句酌訂下的契約，囿於語言文字本身的限制，仍不免有字義模糊之可能。契約中可能出現有待解釋的模糊之處，包含文字疑義（term ambiguity）、文句疑義（sentence ambiguity）、契約結構上疑義（structural ambiguity）及本身字義即模糊文字（vagueness）的使用。

而契約解釋對於契約內容構成之影響，有認為應有三層面。一為「單純的契約解釋」，即就當事人具體有合意的內容為解釋；二是「補充契約解釋」，即就當事人未明示合意之部分，藉「假設的當事人意思」來解釋補充；三則為「契約內容之補充」，即由契約之外的法規範，比方民法上的「任意規定」，來對契約的內容做解釋時契約內容填充<sup>34</sup>。特應敘明，契約解釋是上位概念，包含「單純契約解釋」、「補充契約解釋」與「契約內容的補充」三種解釋之子概念，雖同為對契約做解釋，但理解上仍應區分層次，不宜混為一談，蓋其所面臨之問題及其取徑皆不盡相同。本章擬先就單純的

---

34 參見黃立，民法債編總論，頁77-80（2002年）。

契約解釋此一子概念，及延續前章，討論任意規定於契約解釋此一上位概念中之角色及其與契約解釋之互動。

首先，就單純的契約解釋而言，臺灣民法第98條規定：「解釋意思表示，應探求當事人之真意，不得拘泥於所用之辭句。」<sup>35</sup> 其所謂「當事人真意」應如何解釋，學說有謂係指「客觀上、規範上所具有之意義」，亦即並非表意人內心真正所欲，亦非相對人意思表示事實上所瞭解的意義，而是「一般」相對人在系爭意思表示作成時，斟酌該系爭表示之表示行為及其附隨情況，所構成在客觀上、規範上所具有之意義<sup>36</sup>。亦有論者主張契約解釋目的，在探求當事人真意，不是指當事人內心主觀的意思，而是從意思表示受領人立場去認定「客觀表示價值」，其在於保護交易相對人信賴，維護交易安全<sup>36</sup>。更有強調當事人立約真意的探求，並非探求契約任一方當事人主觀的意思或認知，而應探求當事人共同主觀意思<sup>37</sup>。綜言之，雖臺灣法條明文有「探求當事人真意」似傾向「主觀」立場的契約解釋途徑，但一般學說上仍咸認所謂的真意，應以客觀角度，觀察當事人共同展現在外能被第三人所理解的意思為理解標準。

具體操作途徑上，有學者指出其類似於法律解釋，而將法律解釋之方法運用於契約解釋之領域，做出：1. 契約文義；2. 被解釋的條款在契約中的體系地位；3. 訂約當時的事實及資料，如締約過程、往來文件及契約草案等；4. 交易上同類型的契約條款的比較；5. 契約目的等五項基準<sup>38</sup>。而在實務中，法院亦援引民法第98條當作契約解釋的基本原則，於處理當事人真意與客觀文義的衝突上，傾向應全盤通觀契約全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值等作全盤

35 參見黃茂榮，民法總則，增訂版，頁808-809（1982年）。

36 參見王澤鑑，債法原理（一），頁236-237（2006年）。

37 參見陳自強，契約之內容與消滅，頁77（2004年）。

38 陳自強（註37），頁79。

之觀察<sup>39</sup>；亦有主張解釋契約固須探求當事人立約時之真意，但契約文字業已表示當事人真意無須別為探求者，即不得捨文字而更為曲解之<sup>40</sup>。近來實務見解上，較傾向所謂前者認解釋契約仍應通觀全文，於文義上及論理上詳為推求當事人立約時之真意之看法<sup>41</sup>。

另有學者整理最高法院判決做出如下歸納<sup>42</sup>：1. 仍以契約文義為出發點，先單做契約文義做解釋；2. 再透過通觀契約全文，由整體契約的佈局做體系解釋；3. 斟酌締約時之背景事實及資料，如磋商過程、往來文件及契約草案等，以歷史解釋方式理解；4. 回歸考量契約目的及所追求經濟價值，做出目的解釋；5. 參酌交易慣例，從商業上習慣、類似契約之一般處理方式來評斷；6. 法院在介入評斷時應以誠實信用為指導原則，面對疑義解釋時，應兼顧雙方當事人利益，並使其符合誠信的交易原則。

然而，畢竟民法第98條內容簡陋，又臺灣並非採普通法系，判決實踐原則不具拘束力，故法院在為契約解釋的判斷上，難免有流於恣意之可能，是故解釋標準的法條明文化，或具有必要性。對此，同樣借鏡德國民法而制定的《中華人民共和國合同法》，或有供臺灣參酌之空間，將於後章節詳述之。

39 參最高法院19年上字第58號民事判例、最高法院65年度台上字第2135號判決、最高法院88年度台上字第972號民事判決。

40 參最高法院17年上字第1118號判例、最高法院86年度台上字第3042號民事判決、最高法院96年度台上字第1577號民事判決。

41 參最高法院101年度台上字第2100號民事判決：「按解釋契約，應於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意，並通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從該意思表示所根基之原因事實、主要目的、經濟價值、社會客觀認知及當事人所欲表示之法律效果，作全盤之觀察，以為判斷之基礎，不能徒拘泥字面或截取書據中一二語，任意推解致失其真意。」最高法院102年度台上字第2087號民事判決：「所謂探求當事人真意，乃在兩造就其意思表示真意有爭執時，應從該意思表示所植基之原因事實、經濟目的、社會通念、交易習慣、一般客觀情事及當事人所欲使該意思表示發生之法律效果而為探求，並將誠信原則涵攝在內，藉以檢視其解釋結果是否符合公平原則。」

42 王澤鑑（註36），頁236-237。



## （二）契約解釋與任意規定

實務上於解釋契約時常習於先將契約作定性，有名契約即適用債編各論之規定，若為無名契約則混合各有名契約的特徵，套用入該無名契約後形成一混合契約，再分別適用或類推適用相關法條。然而此種運用任意規定之方式實有檢討之必要。任意規定既係立法者預測典型契約之權利義務分配方式、為填補契約漏洞而設計，則其無可避免的成為契約解釋重要的一環。其滋疑義之處主要出現在兩個部分，首先，何時應該於契約解釋中引入任意規定？其次，仍然存在其他方法時是否應優先使用任意規定？

對於第一個問題，於解釋契約時，首重當事人意思之解釋，契約作為當事人實現私法自治之產物，於雙方存在合意時自以雙方合意之內容為契約之內容，雖有合意但因語意上有模糊之處及其他狀況等等，自依契約解釋探求當事人真意處理，而任意規定應僅於當事人合意所不及之處，即契約存有缺漏、漏洞時登場，僅有在契約存在漏洞時方有考慮任意規定之空間，此乃普遍之原則，而契約是否存在漏洞之判斷，亦仰賴契約解釋<sup>43</sup>。然而，契約存有漏洞時，除了引入任意規定，亦可經由補充契約解釋，綜合文意脈絡、交易習慣等填補之，對於究應優先適用任意規定，或者應以契約解釋補充之，即有爭議。

臺灣傳統契約解釋處理方式上，主要係以國內既有之法律規定為優先參考標準，在解釋契約時逕行適用法條或以法理之類比論證適用；再者，才是對雙方契約內容採「假設的當事人意思」觀點來切入，具體運作所謂補充的契約解釋。而在適用任意規定時，如前所述，往往為有名契約逕依有名契約規定，而若為非典型之無名契約，則綜合其特徵以融合不同有名契約之「混合契約」定性之<sup>44</sup>，

<sup>43</sup> Posner, *supra* note 14, at 568-69.

<sup>44</sup> 此現象尤以工程契約為著例，實務上常混以買賣、承攬等而有如工作物供給契

再依其特性分別適用不同有名契約之規定。此種必得將無名契約套入有名契約框架中的做法，對於處理現代多元化、高度複雜化的契約，實難謂為妥善之方式。畢竟任意契約僅為立法者事前的、概括的對於一般情形所為之預測，然而立法至今商業及產業策略、契約領域之發展都已遠超乎立法者預設，且在許多契約個案中，當事人對於未來情勢、雙方關係之想像未必與立法者相同。

在德國，雖然法院的判決認為，任意法若與補充的契約解釋間的競合時，「通常」或「原則上」優先適用任意法<sup>45</sup>，但另一方面，法院的判決亦承認，例如在合夥契約應優先以補充的契約解釋來填補漏洞，因適用任意法常會造成違反事實的結果，故僅作為最後的權宜措施。同時，亦有法院判決認為若依補充的契約解釋，能得出該契約不欲適用某任意規定之結論時，應排除該任意規定之適用<sup>46</sup>。因此有學者即謂，在契約解釋中，原則上契約的補充解釋優先於任意的法律規定<sup>47</sup>。

總而言之，於契約解釋時欲引入任意規定，需要滿足以下兩個要件：首先，因契約無約定或因廢止定型化條款，而實際上產生契約漏洞。而漏洞是否存在於某些案例並不容易判斷，需要藉由解釋而得。其次，必須於契約的補充性解釋下，不會得出當事人在訂立契約前若可忽略協商之交易成本，對該開放的問題將得出與該任意規定相偏離的約定之結論。<sup>48</sup>在歐陸法中，多有為了在個別案例能做出最符合該案需求、當事人真意之裁判，而選擇自契約本身解釋

---

約之混合型契約存在。可參最高法院102年度台上字第1468號民事判決、最高法院102年度台上字第1147號民事判決等。

45 Vgl. z. B. BGHZ 158, 201 (206) = NJW 2004, 1590 (1591); 176, 244 (Tz. 32) = NJW 2008, 2172 (2175); BGH, NJW 2010, 1135 (1136). Ebenso Reinhard Bork, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 3. Aufl., 2011, Rn. 534 ff.

46 BGH, NJW 1975, 1116 (1117); NJW-RR 1990, 817 (818 f.).

47 Hein D. Kötz, Dispositives Recht und ergänzende Vertragsauslegung, JuS 2013, S. 289 (296).

48 *Id.*

而非適用任意規定之情形，此乃因為契約之複雜性和歧異性可能遠超乎簡潔的立法規定<sup>49</sup>。

而臺灣學者，亦有提出五種不應適用任意法之情形：1. 任意法的規定顯然無助於規範漏洞的排除，因為對於待解決的問題，在任意規定並未包含有客觀上適當的規範；2. 由雙方當事人有漏洞的行為中顯示，當事人不願意接受任意法規則的適用者；3. 法定規範由於當事人錯誤的想法，致其效果與其所尋求者大相逕庭者；4. 具體行為的規範大幅背離法定的行為態樣，以致於法定規範無法得出客觀合理的解決者；5. 任意法的規範不符合改變的經濟關係，以致於契約實務上均不採行時<sup>50</sup>。由此可看出任意規定確實在許多情形下無法最妥適的處理契約漏洞填補的問題。而以上情形固可作為不應適用任意規定之參考之標準，然正本清源之道，仍是避免先入為主的套用任意規定之條文，而係優先考量合乎當事人契約關係之處理方式。

任意規定之立法對於較單純、重複發生之民事契約或簡單的商事契約固然有其意義，但若不加以區分即統一、強制的優先適用任意規定填補契約漏洞而不論契約訂定時之背景、當事人之關係等等，對於現代尤其商事契約之當事人而言，不但無法達成任意法規之立法目的，更可能會使得當事人必須額外付出在所有可能適用任意規定之處協議排除任意規定適用之成本，反而造成任意規定欲節省成本之反效果，產生因任意規定制定之經驗性而導致無法反映當事人雙方的目的，最終成為當事人的隱憂<sup>51</sup>。

因此，綜而言之，在解釋契約之時，若當事人有合意排除，或任意規定本身即要求法院自行補充者，任意規定自無登場之餘地；

---

49 Canaris & Grigoleit, *supra* note 2, at 18-19.

50 黃立（註34），頁79。

51 Grigoleit, *supra* note 13, at 2.

而如適用或類推適用任意規定，將違反契約本身個案特殊目的時，亦不宜適用任意規定，而應以補充契約解釋為優先。至於補充契約解釋之方法，將於下章詳細介紹。

## 二、案例研究——一則經銷契約判決

關於法院慣於操作契約定性之問題，可參考一則關於經銷契約的案例<sup>52</sup>。該案事實主要係瑩圃公司主張與倚天公司備忘錄所定之「最低承銷量」，乃以該數量為契約之標的；但倚天公司反主張，該約定僅在其銷售量未達契約約定時，賦予瑩圃公司得解除契約之權利。對此，最高法院見解認為：

社會上通常稱之「經銷商契約」（或稱代理店契約、代理商契約），係指商品之製造商或進口商，將商品交由經銷商，為商品之販賣。至於其法律性質，依其契約之具體內容，可能有三種類型：買賣、行紀或代辦商。……本案之備忘錄雖然在第一條載有『代理經銷』之用語，惟由其後各條之規定觀之，該備忘錄之性質為何，並不確定，故尚有探究之必要。原審（即高等法院）認該備忘錄為買賣與代理承銷混合之契約，稍嫌速斷。

於此案中，最高法院過分關注於契約性質之「定性」，似乎無助於解決雙方之紛爭。就契約解釋而言，若當事人有契約解釋上意思的不一致時，單就契約文義仍無法明白釐清，則應回歸「締約目的」思考。蓋當事人間備忘錄實屬一不完整契約與長期關係契約，最低承銷量之約定，應是瑩圃公司為確保倚天公司能盡最大努力推廣銷售其產品，即實務上所稱「盡力條款」（best efforts clause）<sup>53</sup>。其實在製造商在無法完整掌握經銷商行為之狀況下，即使經銷

<sup>52</sup> 最高法院97年度台上字第1769號民事判決。

<sup>53</sup> See Paul H. Rubin, *The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise*

商在合約中承諾將「盡力而為」，亦難以認定是否違反此義務，故契約內約定「最低承銷量」條款，不失為一個可防範道德風險之操作標準。

循此，最低承銷量之約定亦可發揮風險轉嫁之機能，讓瑩圃公司能事先預測其每月之最低銷售收入，作為後續現金支出規劃之基礎；並使倚天公司負擔一定業績壓力，在未達最低承銷數額時，即需負擔該部分支出之風險。本件中倚天公司並未盡力完成契約中所約定之最低承銷額義務，解釋上應認其有違約之情，故瑩圃公司當可依債務不履行之規定，向倚天公司請求終止契約及損害賠償。如此處理始符合雙方締結經銷契約之商業考量與經濟邏輯，若耗大量精力去進行契約定性以便援引契約法上的任意規定，不無削足適履之虞。

### 三、契約解釋——比較法觀點

#### （一）前言

傳統上認為，英國與德國分別立於契約解釋途徑光譜之兩端<sup>54</sup>，即英國契約法因重視商業市場第三人對交易的外觀認識，而採取較極端的「客觀」途徑；德國則因歷史背景上多由商人擔任法官的商事法庭常僅就契約字面上意義就為判決，故基於衡平而強調應採探求當事人真意之「主觀」途徑。

而由此，衍生出在契約解釋的一般性原則上，存在三個二極對立的標準，此三者傳統上以英德分別為光譜的兩端，代表著從不同

---

*Contract*, 21 J.L. & ECON. 223, 227-30 (1978). 本文所討論者雖為加盟契約，但亦可用於分析經銷契約。在法經濟學上，兩者同屬於垂直契約，差別僅在於經銷契約之「垂直性」較低。

<sup>54</sup> See Gerard McMeel & Hans Christoph Grigoleit, *Interpretation of Contracts – Prospective European Regulation from the English and German Point of View* 1 (Mar. 1, 2013), <http://ssrn.com/abstract=2221051>.

歷史脈絡下發展出來，對於解釋契約時相衝突的價值所作之不同取捨。其一，為「明確性（certainty）」與「公平性（justice）」之對立，蓋於契約內容當中，雖當事人多有對雙方應負的權利義務內容為明確性規劃，但如此規劃有時可能對當事人一方存有顯著的不公平，在尊重私法自治下契約自由和維持社會公平正義的任務間，應如何調和乃是首要問題。其二，是解釋契約時應由「客觀（objective）」或「主觀（subjective）」來切入的對立，即究應客觀直接從契約外觀上顯現的內容來評價，還是應固守以當事人締約時主觀的想法做標準。其三，是契約內容「文義（textual）」與「背景脈絡（contextual）」的對立，即解釋契約文字時，應抉擇是否優先以其用詞本身文義為準來詮釋，還是須回歸到契約整體背景脈絡，來理解用字遣詞以避免文字誤用產生誤解。上述三個標準，可謂從契約解釋中最上位的抽象觀點，逐步落實到具體契約內容的觀察，以下即詳述兩國之背景及特色。

## （二）英國法下的契約解釋

英國法因是普通法系的代表國，故司法判決的做成仰賴判例法的累積實踐。其中對於契約解釋的原則，主要奠基於 *Investor Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society*<sup>55</sup> 一案。在該案中，Lord Hoffman 對契約的解釋提出了五項標準：1. 解釋契約應從確定的契約文件傳達給當事人時，依其所擁有相關背景知識地位的第三人所能理解的意義出發；2. 解釋時參酌的背景事實應包括所有影響文件使用語言認知上之事物；3. 當事人主觀上單方面真意的展示亦應被考量；4. 契約文字意義應在相關背景下做合理解釋；5. 文字錯誤不能被輕易的接受為契約內容，除非顯為當事人真意。

---

<sup>55</sup> See *Investor Compensation Scheme Ltd v. West Bromwich Building Society* [1997] UKHL 28.

具體運作而言，英國在契約解釋的主觀與客觀對立上，採行的是較嚴格「客觀說」的基準。即當契約約款內容有明確字義，並無模稜兩可之處時，基於「當事人亦如一般人般合理使用語言或文法」之假設，即以契約文字之通常合理字義做解釋。惟當約款有模糊矛盾處，比方一詞有兩種以上合理字義時，除參考使用語境、字典註釋等影響遣詞因素外，則有必要回歸考量當事人主觀意思，並輔以所有相關事證加以理解，比方當事人交易往返的過程、履約行為、以及商業習慣。又在用詞上，若契約內容形式上有自相矛盾、用語缺乏定義等情形，稱為明顯多義（*patent ambiguity*），此時契約常被認為不明確而無效。須注意者，乃當事人有自行為特定條款約定時，則解釋上應更為謹慎，如與常見的契約約定條款有抵觸時，特別條款原則優於一般意義條款。

### （三）德國法下的契約解釋

德國法下的契約解釋原則，主要由德國民法第133條與第157條構成。其第133條內容為：「解釋意思表示應探求真意，不得拘泥於所用詞句。」第157條則明定：「解釋契約應該依誠信原則及交易習慣為之。」單就文義上來看，第133條規範的主要是當事人意思表示的解釋，其目標在針對表意人之真意，探求可以適用於個別意思表示、契約、各種法律行為之一般解釋原則；第157條之規範，則是針對補充性解釋而發，重在綜合與調和當事人之意思表示，透過以誠信原則為核心的假設的當事人意思，來解釋契約的內容。不過德國學界一般認為，兩條文並非獨立的規範，而是可以相互競合用以整體解釋契約。

將兩條文結合的具體適用上，應該先按第133條對當事人經驗上的真意做解釋，再依第157條做對客觀規範上的真意做解釋，兩者的內涵可相互補充，因解釋意思表示同樣需要考量誠信原則與交易習慣。進一步言，在德國法中藉意思表示做成的法律行為解釋

上，具有決定性地位的是當事人本於「自我決定及自我負責原則」主觀所形成的合意內容；相對的，客觀上「交易安全暨信賴保護原則」，則列後受考量。即在尊重當事人主觀意思的情況下，若別無值得保護他造信賴與交易安全之情，第133條所揭櫫的當事人主觀真意應優先被考慮為契約解釋基準；但若相對人具交易安全保護之必要，契約解釋上則不應受字義拘泥，而應客觀考量誠信原則以解釋。整體而言，德國法下的契約解釋，可謂是一種主觀中又帶客觀的解釋方法。

再就德國實務實踐觀察，德國民法第133條所謂意思表示的「真意」，事實上已不再被完全解為表意人內心的意思，毋寧是指當事人「真正被表示在外的意思」。換言之，即當事人真意的判斷上，是由法官考量指涉法律行為內後，就經濟上具有合目的性與正當者論之。是故，可謂德國法院探求的當事人真意，其實更傾向是「假設的當事人意思」。假設的當事人意思解釋，秉第157條交互參照，應講究誠信原則及交易習慣，從一個客觀的觀察者角度，來考量相對人可能如何理解意思表示。換言之，即契約解釋出之內涵，一方面應是表意人其公正地可能預測或理解之意義；一方面應是相對人在必要謹慎考慮下，所可能理解知悉的意義。

經過以上檢討，似可認強調絕對的主觀說已式微，在當今契約解釋方法上，英、德兩國毋寧是皆本於「理性第三人」對契約所能理解的內容，為解釋之基本路徑。而臺灣民法第98條雖似是自德國民法而來，但規定卻顯然較德國民法簡陋，此可能係臺灣於契約解釋時法院恐失之於恣意之原因，或可參考而做更完整之規定。



## 伍、契約（法）解釋第三部曲——慎選漏洞填補的方式

### 一、契約漏洞的填補——通說

如前所述，契約既然是為了確保未來的履約而生，而未來又充滿不可預測性，則契約本質上就必定帶有解釋的問題以及漏洞的出現。蓋因處於現實生活中，預測未來的困難及其所耗費的成本，以及締約雙方協商的成本皆不可能為零，使得締約者必須在「交易成本」及「契約完整度」之間做出取捨<sup>56</sup>。一如德國學者Hein Kötz所言：「契約的不完備，並非是由於當事人懈怠或非理性，而是因為談判完整活動的過程並不經濟，會產生巨大交易成本。<sup>57</sup>」

所謂契約漏洞，係指當事人依其契約目的及計畫，本應約定卻漏未約定之情形。而其與一般契約解釋之情形最大之差別在於契約解釋上有契約文字可作參考，但契約漏洞卻付之闕如，無文字可循。除此之外，契約漏洞也可能發生在契約一部無效的情形，即當事人雖對該事項有約定，但約定內容因抵觸法律強制或禁止規定而一部無效，或定型化契約條款因違反相關規定而無效之情形<sup>58</sup>。

而關於契約漏洞的填補，民法第153條第2項規定：「當事人對

---

<sup>56</sup> Richard A. Posner, *The Law and Economics of Contract Interpretation*, 83 TEX. L. REV. 1581, 1583 (2004).

<sup>57</sup> Vgl. Kötz (Fn. 47).

<sup>58</sup> 例如違反消費者保護法第12條：「定型化契約中之條款違反誠信原則，對消費者顯失公平者，無效（第1項）。定型化契約中之條款有下列情形之一者，推定其顯失公平：一、違反平等互惠原則者。二、條款與其所排除不予適用之任意規定之立法意旨顯相矛盾者。三、契約之主要權利或義務，因受條款之限制，致契約之目的難以達成者（第2項）。」或民法第247條之1：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」

於必要之點，意思一致，而對於非必要之點，未經表示意思者，推定其契約為成立，關於該非必要之點，當事人意思不一致時，法院應依其事件之性質定之。」此即認契約出現漏洞時，應由法院補充之。有認法院可能自行依衡平法理判斷，亦有認為此即謂法院以任意法規、習慣、法理為標準決定之，即依前述之任意法規，或者契約補充解釋加以填補<sup>59</sup>，此二者乃為填補契約漏洞之主要方法，若欠缺任意法時，則僅能考慮補充的契約解釋，而若漏洞是因定型化條款的無效而產生時，亦適用補充的契約解釋。例如，新車出賣人依據定型化條款內容的規定，在締約日與交付日間相距逾四個月時，得請求適用交付日價目表金額為賣價。若此條款無效而造成契約漏洞時，且欠缺得以填補該漏洞的任意法規規定。這時應允許補充的契約解釋存在。

而所謂契約的補充解釋即以「假設的當事人意思」，考慮交易過程與商業習慣等來做補充契約解釋，而假設的當事人意思，承前述，即雙方當事人在通常交易上合理所意欲或接受的意思，係「當事人地位所應擁有相關背景知識的理性第三人理解意義」。德國法上亦採取此補充解釋契約之方法，而其假設的當事人意思，係「關於調查與考量當事人雖然未表示全部的契約目的，然契約整體的意旨做成的解釋，亦即當事人就未約定事項亦會做相同約定，並同時注意誠實信用原則與交易習慣」<sup>60</sup>。

而在理解契約之意指時，應認識到契約當事人締結契約之目的往往在於極大化自身利益，確保締約前之交易相關投資與締約後之交易進行，均能以最有效率的方式為之。是故，在以假設的當事人

<sup>59</sup> 王澤鑑（註36），頁244。

<sup>60</sup> BGHZ 16, 71 (76) = NJW 1955, 337; 84, 1 (7) = NJW 1982, 2184 (2185); 127, 138 (142) = NJW 1994, 3287; 158, 201 (207) = NJW 2004, 1590 (1591 f.); BGH, NJW 2004, 2449; BGHZ 164, 286 (292) = NJW 2006, 54 (55) = JuS 2006, 177 (Emmerich); BGH, NJW-RR 2008, 562 (Tz. 15); BGH, NJW-RR 2005, 205 (206).

意思填補漏洞時，不妨引入經濟分析觀點來作為假設當事人意思之參考，引進經濟分析的概念工具，例如「資訊不對稱」、「逆選擇」、「道德危險」、「特定性資產」等，以利於更加合理的理解當事人行為、意思，從當事人經濟目的出發，合理的解釋契約漏洞。

而應注意者，假設的當事人意思需與默示的意思表示相區別，默示的意思表示可能自當事人之行為得出，而若雙方有默示意思表示合致，則該處即不會形成契約的漏洞。在進行契約漏洞填補之前，亦需要特別注意在某些情形下契約的缺漏可能源於雙方意思表示不合致，而當此不合致涉及契約的必要之點，又無法透過解釋填補時，契約即有不成立之可能。此時，即非契約漏洞填補之問題，而應是雙方意思表示解釋之問題。然而此情形並不常見，首先因為契約雙方本身即應會注意到他們對於契約必要之點的歧異，另一方面，契約解釋的一重要原則要求雙方的意思表示必須以理性第三人之觀點去理解，此也使得契約解釋比較不容易出現雙方意思表示未合致之結果<sup>61</sup>。

## 二、案例研究——一則保證契約判決<sup>62</sup>

此為一關於保證契約之案例。本案中，上訴人臺北市養工處（後移轉業務由水利處辦理）與天太營造公司（下稱天太公司）簽訂工程合約，承攬「社子島防潮堤加高工程（第四標）」。上訴人並委請被上訴人寶島商銀（後更名為日盛銀行）出具工程保證金保證書，就該履約保證金負擔保責任，約定被上訴人日盛銀行收到書面通知十日內即應支付保證金。保證書中並有約定，養工處得自行處理該款，無需經過任何法律或行政程序，寶島商銀絕無異議且願放棄民法第745條之先訴抗辯權。嗣後天太公司未依約施工，養工處乃終止契約，催告保證人日盛銀行支付全額履約保證金。保證人乃

<sup>61</sup> Canaris & Grigoleit, *supra* note 2, at 17-18.

<sup>62</sup> 最高法院102年度台上字第584號民事判決。

主張：一、依據民法第741、742條關於保證契約從屬性之規定，保證人不得負擔較主債務人為重之責任；二、主契約之保固期已屆滿，保證責任隨之消滅為由，拒絕負擔保證責任。債權人養工處則主張本案之保證書具為「立即照付擔保契約」，與一般具有從屬性、補充性的民事保證契約不同。

綜上，本案爭點即為系爭「工程保證契約」是否與一般保證契約性質相同，而受從屬性、補充性之適用。本案纏訟六年而歷審法院對此見解互異，最終最高法院判決上訴人（臺北市水利處）勝訴。其判決理由略為：「系爭保證書具有獨立性及無因性，係屬付款之承諾，為現金之代替。被上訴人一經上訴人書面通知即有如數給付保證金之義務，而非履行天太公司之承攬契約義務<sup>63</sup>。……立即照付之擔保，具有獨立性，與保證契約具從屬性不同，尚不因其使用『保證』二字或贅列民法第七百四十五條規定而異其認定」。雖是如此，本案歷審法院亦有不少採取「該保證契約具從屬性」之見解，認為保證責任待工程完工，承攬契約保固期滿後，即告終止而消滅<sup>64</sup>。實務上之所以出現兩種殊異之見解，本文認為其根本原因即在法院於解釋契約時仍拘泥於民法任意規定之套用，未能回歸當事人締約之經濟實質為適切之契約解釋。

本案中，上訴人與被上訴人間簽訂之「工程保證契約」，實為工程實務上為因應商業保證之特殊性發展出的一種「銀行保證」，係由銀行擔任信用加強者為債務人擔保債務。此種保證契約所針對的商業行為，涉及企業組織之現金流（cash flow），故若事涉「理賠」問題時，「迅速」與「確實」係商業保證之核心要求。因此，銀行保證經常藉由契約條款修正民法預設之規定以跳脫權利確定程

---

63 相同見解參最高法院98年度台上字2098號民事判決。

64 臺灣高等法院97年度重上字121號民事判決、最高法院100年度台上字第199號民事判決。

序，便於債權之請求<sup>65</sup>。保證人所負之責任在此性質下之解釋，多已偏離傳統保證契約之備位責任，即便保證人並未強調拋棄民法第745條之先訴抗辯權，仍應認具有「獨立性」，並且更重視契約之「文義性」。就獨立性而言，係指該保證契約與原基礎契約各自獨立存在，互不從屬；而文義性，則表示當事人間權利義務的認定，僅依循該保證書所載之條款進行審查，即形式審查之方式。

銀行保證與傳統民事保證之主要差異在於，民法中立法者所預設的保證契約係以「保護保證人」為出發點，而非為追求整體效率。在補償關係上，肯認保證人對債務人之求償地位；在信用加強關係上，保證人享有先訴抗辯權而負備位責任。除此之外，保證人甚至得以保證契約事項之外，主契約中債務人所得主張的抗辯事由對抗債權人。此種規範模式除了使債權人衍生較高執行成本外，亦使得整體風險分擔之三方關係效率有所減損，增加釐清權責的困難，並可能使信用加強功能喪失。學者Aver Katz即認為，銀行保證（或其他商事保證）乃保證人基於資訊優勢下的專業化分工產物<sup>66</sup>。申言之，在工程保證關係中，保證人（通常為金融機構）在資訊優勢下，具有較佳的風險規避能力。例如，擁有完善的債務人債信紀錄或對於債務人的資金運用具有較佳之監控能力。債權人或債務人基於降低交易成本之考量，便樂於促成債權人與保證人間的「合作模式」。在保證人介入下，債務人較容易取得締約機會，債權人亦能有效轉嫁風險，而保證人則藉由自身的資訊優勢在預期損失與利息收益間賺取利差。

---

<sup>65</sup> 例如本案例中之保證書第2條，即有類似約定，一旦承攬人違約，銀行即依機關書面通知所載金額如數撥付，絕不推諉拖延，且無須經過任何法律或行政程序。

<sup>66</sup> See generally Avery Wiener Katz, *An Economic Analysis of the Guaranty Contract*, 66 U. CHI. L. REV. 47 (1999).

本案銀行在保證金支付以外，另出具載有「立即照付條款」之保證書，以紓解承包商籌措資金的壓力，同時增加債權人之締約意願，其契約架構乃在資訊不對稱情況下，藉由引入具有資訊優勢之保證人，以降低交易成本避免「逆選擇」之適例。就此而言，最高法院自當事人締約之經濟實質進行分析，認為本案之保證契約異於傳統保證契約，足資肯定。本文援引此案例之目的在於強調，於解釋契約時，定性契約或者判斷是否援用任意規定時，務求謹慎考量契約背後之經濟實質，甚至應適時捨棄任意規定的類比推理，而強調回歸契約本身推斷「假設的當事人意思」來為判斷，切忌落入「寧可誤引法條，拒絕適切解釋」之亂象。

### 三、比較法觀點

#### （一）英國法

承前所述，英國法的契約解釋主要是基於「客觀」立場，故契約內容的解釋，需以處於相同地位之理性第三人就契約觀察所能理解的內容出發。而對契約內容條款的觀察，英國學理上主要區分為「明示條款（express terms）」和「默示條款（implied terms）」，前者即為契約當事人有明確合意，具體表現在外的契約內容；後者則是當事人在契約中沒有明確約定，而須根據明示條款或直接根據法律推定而形成的契約內容，此即英國法上面對契約不完備填補所採之方式。默示條款一般區分為兩類，一為「事實默示條款」，即法院基於契約的明示條款和案情推定，當事人之間的雖未明確表示出來但卻應該存在的契約條款；另一為「法定默示條款」，即立法者透過法律預設的規定，直接讓法條規範的內容成為契約之條款。

事實默示條款主要有標準有二，第一為「商業效用標準（business efficacy test）」，即法院在解釋默示條款內容以填補漏洞時，應注重契約目的是使交易具有當事人雙方在任何情況下，都希望達到的效用，且當事人追求的商業效用必須有「必要性

(necessity)」；第二為「好事旁觀者標準 (official bystander test)」，此強調默示條款的內容必須是明顯且無需說明的，即假若在談判時有「好事旁觀者」在旁為契約當事人制定契約條款提供意見，當事人必會覺得理所當然而無須於契約中贅述的內容。相對而言，法定默示條款係將判例法、成文法所形成的條款規則，引入當事人未明示約定的契約內容。其中，因英國係普通法國家，故透過判例形成不少契約中當所存在的內容，而經長期的反覆適用者甚至變成文化<sup>67</sup>，而需注意的是受成文法效力所及契約，並不似事實上默示條款需受一定標準檢證，只要未經當事人明示條款排除，則一律自然成為契約條款內容。至於以習慣作為默示條款內容，在英國法上較為困難，基本上必須契約中沒有以明示或必要的默示條款排除慣例的適用，且慣例與契約的總體意旨相符合。

總體而言，因判例與成文法累積得作為默示條款的內容畢竟有限，未必能一體適用型態日益繁複的契約，是故乘於當事人意圖而推斷的事實上默示條款，相較法定默示條款仍較為重要。雖默示條款制度某程度介入了私法自治原則，但從英國法院在適用上力求尊重當事人意思，在其明示意思確有模糊時，才推斷當事人意思進行彌補、完善與修正，並強調追求契約當事人的商業效用實現，是有一定在契約自由與公平正義間調和，妥善的化解當事人契約漏洞紛爭，甚至某種程度上藉以實現政策傾向目標。

---

67 《1973年貨物供應（默示條款）法》(the Supply of Goods (implied terms) Act 1973)、《1977年不公平契約條款法》(Unfair Contract Terms Act 1977)、《1979年貨物銷售法》(Sale of Goods Act 1979)、《1982年貨物和勞務供應法》(the Supply of Goods and Services Act 1982)。《1979年貨物銷售法》在對其之前的幾部相關法規進行修訂的基礎上，最終奠定了當今英國在貨物買賣領域法律規則的基礎，其中第12至15條規定的默示條款亦成為貨物買賣領域成文法上默示條款的主要淵源。

## （二）德國法

德國作為大陸法系代表國家，在契約漏洞的填補上，主要即仰賴任意規定的援用和假設的當事人意思補充。傳統上若為有名契約，在當事人未特約排除情況下即逕以任意規定對當事人約定不足之處為補充；而在任意規定尚無法補足之時，方由法院藉判斷假設的當事人意思填補。而在無名契約中，因沒有具體的任意規定可供對照，故漏洞填補方式即產生分歧，究應就無名契約之特徵比對既有有名契約來定性，並類推有名契約的任意規定來補充漏洞，再有不足才引假設的當事人意思以為判斷；還是應直接以假設的當事人意思加以判斷，而毋須再參考法條上之任意規定，滋生疑義。其似無如臺灣直接以有名契約定性後套用有名契約任意規定之情形。

然而對此，德國當今見解對任意規定的適用似益發採取謹慎態度。承前所述，學者有謂即便是存在任意規定的場合，任意規定也只應在符合兩項條件時才能被當然解為填補契約漏洞之條款。第一，須契約漏洞確實存在，第二，當事人在不考量交易成本時所欲訂立的契約不會明顯偏離該任意規定。而於此情形，「補充契約解釋」或許便是填補契約漏洞最合適之方式。如前所述，德國法所採補充契約解釋之方式乃係假設的當事人意思，即「當事人在整體契約、最大化誠信原則與交易習慣的共同考量下所可能採取之意思」<sup>68</sup>，亦即法官必須透過契約解釋探求當事人的真意。此處所涉及的並非事實的解釋，而是法官對契約未規定的事項，依據規則做出合適且公平的解決方式。此外，亦須注意，法官使用補充的契約解釋並非用作「形成契約的空白文件」或「作為契約當事人束縛（Gängelung）的工具」，解釋契約不得牴觸事實上所做成的約定、不得擴大契約、應著重於當事人雖未規定，但於其真意範圍內應需規定的事項。法官不能因為認為協議具有意義，或不想更正當事人

---

<sup>68</sup> Canaris & Grigoleit, *supra* note 2, at 19.



在締約時因不注意、粗心或冒險所造成的錯誤，就認為在契約中存在協議<sup>69</sup>。

而因此補充契約解釋方式除尊重當事人雙方可理解意思外，秉於德國民法157條更應考量誠信原則與交易習慣，故法院對於契約漏洞的填補，應亦能力求私法自治與社會公義之平衡，不致因不當然適用任意規定即無法兼顧社會公平正義。

以具體著名案例「醫師交換診所案」為例，在德國，其於透過契約解釋填補漏洞時會以誠信原則、交易習慣作為輔助解釋和建構出當事人一般而言會合意的契約內容。例如1954年的醫生交換診所案中，在A地開業之甲與在B地開業之乙約定互換診所，甲在B地執業九個月後又返回A地原診所附近重新開業，乙主張甲有不得在原診所附近開業的不作為義務，雖無法律明文、其契約亦無約定，然德國聯邦法院認為甲乙之契約雖未就此為約定，但衡諸契約，其契約目的絕非單純只於營業場所、生財器具設備、病患資料等之取得，而應包含讓彼此在互換之地職業，與病患間的關係處於與他方相同的地位。甲乙對返還原地重新開業的問題並非有意不規範，而應係契約漏洞。而此契約為無名契約，無任意規定可適用，法院便以假設的當事人意思認為當事人在考量契約整體目的，並斟酌誠信原則與交易習慣，應該會約定在互換診所二至三年內不得重返附近開業，認定甲有該不作為義務<sup>70、71</sup>。

除德國外，在法國，法院也擁有解釋、建構契約內容的空間。例如在1974的一個案例中，法院判決一個與作家訂定契約要求作家

---

69 Vgl. dazu ausf. z. B. *Bork* (Fn. 45), Rn. 537 ff.

70 Vgl. BGH, 18.12.1954, BGHZ 16, 71 (76).

71 陳自強（註37），頁87-88。

寫出廣播劇，且已無異議的受領該劇並支付對價的電台應該要播出該劇，儘管契約中並未對此有明確的合意<sup>72</sup>。

## 陸、差別待遇？商事與非典型契約的解釋

### 一、民事與商事契約的雙元發展

契約是一種以互惠原則為基礎的社會分工，為建構人類社會生活的基本要素，並以契約法作為確保履行的憑藉<sup>73</sup>。如前所述，契約法最核心的法理係私法下之「契約自由原則」，即在私法關係中，個人利用契約取得權利、負擔義務，純由個人的自由意思決定。但縱使契約法強調契約自由，仍對於契約自由設有界限，即無人可在不遵守法律規定的情況下享受完全的契約自由，事實上也不存在法律完全沒有規範、完全可以由個人自由商定契約的空間<sup>74</sup>。

此外，是否有實質的契約自由亦取決於當事人是否能立於平等地位締約，由於現今資本主義自由經濟之發展，而產生經濟能力強弱差距擴大的現象，締約雙方立於不平等之地位時，可能強者會假契約自由之名行剝奪、限制弱者權利之實，造成不公平交易的結果，故須限制契約自由，以實踐契約法之機能<sup>75</sup>。但並非所有的契約類型都會出現如上所述契約雙方經濟地位不平等之問題，於契約雙方皆為經濟上強者之情形，當事人較不需受到法律之保護，應放寬契約自由之限制，由雙方自行約定。

---

<sup>72</sup> Vgl. Cour de cassation [Cass.] [Supreme court for judicial matters] le civ., Apr. 2, 1974, *Bull. Civ. I*, n° 109 (Fr.).

<sup>73</sup> 參見Thomas Raiser著，高旭軍等譯，法社會學導論，5版，頁235-237（2011年）。

<sup>74</sup> Thomas Raiser著，高旭軍等譯（註73），頁238。

<sup>75</sup> 王澤鑑（註36），頁80-81；劉春堂（註24），頁34-36。

當事人情況各異，契約法自不宜對它們等量齊觀，因此出現了民事契約與商事契約雙元發展的現象。近年來「國際統一私法協會」(UNIDROIT)另闢蹊徑，制訂「國際商事契約通則」，與以強行規定為主的消費者契約做區隔，此區分彰顯出商事契約不同於民事契約，具有更大的當事人自治性與任意性。

商事契約是所有商業活動的基礎與準繩，因此無論是契約法規範商事契約，或者是法院解釋商事契約，均應符合締約目的，體現契約所蘊含的商業考量與經濟邏輯，以促進商業活動的發展。

## 二、解釋民商事契約的差異

臺灣民法制度係採取所謂的「民商合一」制度，而沒有獨立的商法典存在，因此商事契約同一般的民事契約均一體適用民法典中的相關規定。在此制度下，商事契約的特殊性易被忽視，商事契約雖與民事契約都屬於私法契約，但此二者仍有本質上不同之處，如商事交易重視交易簡便、法律安定性且有較強烈的信賴保護需求<sup>76</sup>，若無視此商事行為的特殊性而一味機械性地適用民法一般規範，將造成不公平的結果，因此有必要將商事契約與民事契約兩者加以區別，尤其是在解釋契約時更應注意此二者之差異。

所謂的商事契約係指締約雙方皆為老練的經濟人(sophisticated economic actors)的契約，即學說上所謂的雙方商事契約。與一般的民事契約相較，此種屬老練的經濟人之廠商具有較強的談判能力，與締約他方廠商資訊地位平等，較不需契約法強行規定的保護，注重契約自由或當事人自治原則，且此類型當事人擁有事前評估風險的能力及工具，並會設計適當機制以分散或規避風險，為了使其商業運作能有效面對瞬息萬變的市場，訂立之契約通

---

<sup>76</sup> 參見陳自強，民商合一與民商分立，月旦民商法雜誌，10期，頁91-92（2005年）。

常會事先規畫特殊機制以因應未來可能產生之風險或無法評估之不確定因素，所以契約內容通常比一般的民事契約複雜<sup>77</sup>。

商事契約往往具有特殊且複雜的風險管控或分配機制，屬於法律未明文規範並基於契約自由原則創設的非典型契約，且多為不完整契約，存在漏洞有待填補。此種新型態交易之締約背景與目的遠非立法者制訂契約法時所能設想，如仍僅以任意法規作為漏洞填補之主要依據，恐造成與交易現實、本質相悖之結果，甚至可能違反契約目的，並且對於交易創新造成不利影響。因此，如前所述，漏洞之填補不應只援引任意規定，而宜探求當事人真意所在，另為契約的補充解釋。在商事契約中，當事人最大的目的是要極大化交易之利益，確保締約前之交易相關投資與締約後之交易進行，均能以最有效率的方式為之<sup>78</sup>，這是契約法所應達成之目標。因此，相對於民事契約，於解釋商事契約時應特別注意尊重當事人自治，並參酌契約之締約目的、交易過程（course of dealing）、商業習慣（usage of trade），將非典型契約（特別是混合契約之類型）視為單獨的契約類型，置於廣義的交易脈絡下理解，以契約本身為契約補充解釋之起點，且於解釋契約時，可納入經濟分析之概念，例如資訊不對稱（asymmetric information）造成的逆選擇（adverse selection）、道德危險（moral hazard），以及特定性資產（asset specificity）等<sup>79</sup>，以求更加符合商事契約之特性及需求，有利於產業發展及契約法目的之達成。將經濟分析之概念引入商事法中，於比較法尤其美國似已為顯學，相關學者及論述甚多，然於臺灣似乎仍未受足夠之重視，實則商事領域，難以與經濟學研究之範疇涇渭分明之劃分，若能引入經濟分析之概念，正視商法之特殊性，實為

77 參見王文字，商事契約的解釋——類比推理與經濟分析，月旦法學雜誌，236期，頁15-16（2014年）。

78 Alan Schwartz & Robert E. Scott, *Contract Theory and the Limits of Contract Law*, 113 YALE L.J. 541, 545 (2003).

79 詳細內容，可參見王文字（註77），頁5-29。

處理性質迥異之民商事契約之良策。

以加盟契約為例，加盟契約乃現代商業活動所產生的新興交易型態，其屬一種非典型契約，且因其係由典型契約如買賣、租賃、勞務、委任、合夥等契約與非典型契約如授權契約之部分所構成之契約，故亦屬一種混和契約<sup>80</sup>。混合契約在適用法律之方式學說上有吸收說、結合說、類推適用說，通說採類推適用說，即就混合契約之各構成分子類推適用關於各典型契約之規定。但有學者認為未有一說可單獨解決混合契約適用法律之問題，應依其利益狀態、契約目的及斟酌交易慣例決定適用何說較為合理<sup>81</sup>。實務之判決在面對加盟契約的法律適用問題時，遇到契約未約定之爭議，多傾向以爭議事項與何種典型契約之性質類似而準用之<sup>82</sup>。然而，實務上的操作方式忽略加盟契約涉及多種契約特性，包括商標或服務標章的授權，加盟網路系統的共用，此背後更涉經濟學對介於組織與契約之間的混合體（hybrids）的分析，非可一概而論，若欲從與典型契約性質的比較來探求，恐會反陷於治絲益棼之窘境。因此，有學者建議於解決加盟契約之法律適用問題上，應注意加盟是一個基於持續性契約關係所組成，在個別契約之內部關係裡存具有垂直指揮與合作關係，在個別契約之外部則又產生相互連結之組織關係，縱在銷售上係以一致性之系統形象出現，但在法律上卻為各自獨立之個體，因此解決法律適用問題時，最重要的是回歸加盟契約之目的，從傳統個別性加盟契約擴大到加盟網路之系統下，為其權利義務關係描繪出框架，同時參酌加盟契約之目的與特徵並依誠信原則針對個案予以分析與評價<sup>83</sup>。

---

80 參見向明恩，加盟契約在臺灣司法判決帶來之民事爭議——從加盟契約之目的出發，月旦法學雜誌，238期，頁140（2015年）。

81 王澤鑑（註36），頁124。

82 參臺灣高等法院88年度上字第327號民事判決、臺灣高等法院90年度上字第1156號民事判決、臺灣臺北地方法院100年度北簡字第7474號民事判決。

83 向明恩（註80），頁155。

綜上，在處理混合契約、無名契約之時，應優先斟酌該混合契約之契約目的、產業背景與商事習慣，不應一概以該契約某構成部分符合某種典型契約而當然適用其任意規定，否則將阻礙日新月異的商業環境中新型契約之產生。且當數個典型契約特色混合於同一典型契約時，不僅產生量變現象，亦會發生質變的效果，如此將相去當事人原意益發遙遠，恐非吾人所樂見。

## 柒、相關概念的釐清

### 一、請求權基礎

請求權基礎，指可供支持一方當事人向他方當事人有所主張之法律規範，其乃權利之表現，而非與權利同屬一物，於臺灣民法中，學說上認為根據其所由發生基礎權利的不同，可分為債權請求權、物上請求權、人格權上的請求權及身分權上的請求權等。而於債法中，典型之債權請求權即例如法定之債中不當得利請求權、侵權行為損害賠償請求權等<sup>84</sup>。至於意定之債中，傳統上認為契約上請求權基礎之尋求，應先認定該契約究竟是屬於何種典型契約、非典型契約或混合契約之類型<sup>85</sup>，並依該法律規範主張其權利。認定契約類型的過程中，即須透過契約解釋與契約法解釋之操作，若有契約漏洞，傳統通說認為在典型契約原則上應優先適用任意法規，再依契約的補充解釋加以填補<sup>86</sup>，但若係非典型契約或稱無名契約，如前所述，臺灣司法實務上習於以典型契約即有名契約定性之，再適用該任意法規；而於無任意法規時則依補充契約解釋，本

---

<sup>84</sup> 王澤鑑（註18），頁100-101。

<sup>85</sup> 參見王澤鑑，法律思維與民法實例——請求權基礎理論體系，2版，頁60、92（2010年）。

<sup>86</sup> 王澤鑑（註36），頁246。

於當事人合意所形成的契約內容，解釋契約上法律關係應如何履行<sup>87</sup>。以有名契約定性契約之弊，本文著墨頗多，此姑不贅，總而言之於解釋契約時仍應盡可能顧慮當事人之意思，避免套用任意規定。然而此處即生若依傳統民法分析案例以請求權基礎出發之慣習，於有名契約固然有條文依據可成為當事人之請求權基礎，然則於未套用任意規定，或依個案情事必要而須以補充契約解釋填補契約漏洞之情形，此無名契約或甚至部分有名契約之當事人是否即無請求權基礎可言之疑義。

以法律規範作為當事人請求權基礎之依據，於法定之債之情形固然重要，然而於注重當事人自主、作為當事人間權利義務關係分配之意思表示之意定之債即契約，以法律規範作為當事人請求之唯一依據似乎未盡合理。民法既肯認私法自治，肯認當事人間以契約、意思表示和致之方式安排權利義務關係，於意定契約之中，應肯認契約本身即得作為當事人據以主張、請求之依據，而本於假設的當事人意思之補充的契約解釋自然亦得作為請求權基礎，此肯定當事人契約合意之意義並協助其實現之作法，更係自羅馬法來即受肯認之傳統<sup>88</sup>，如此方能真正落實保障私法對於當事人自治之保障。

## 二、誠信原則

臺灣民法第148條第2項關於誠信原則規定：「行使權利、履行義務，應依誠實及信用方法。」並未有如德國民法第157條：「契約應依誠實信用，並顧及交易慣例的要求而解釋。」般明確交代誠信原則與契約解釋之間的關係之規定。而學者王澤鑑指出民法第184條第二項之規定表彰了誠信原則由債權行使及債務履行擴大及於權力的行使及義務的履行，而誠信原則具有三種規範功能：補充功能

---

87 王澤鑑（註36），頁246。

88 Grigoleit, *supra* note 13, at 5.

可創設從給付義務與附隨義務（保護義務），形成法律關係、調整功能則可順應情事變更依當事人聲請調整其間之法律效果、限制及內容控制功能則使誠信原則作為所有權利的內在界線，控制權利行使，而此之判斷則應客觀衡量當事人之利益而認定<sup>89</sup>。

實務上對於誠信原則，則認為係：「……法律倫理價值之最高表現，具有補充、驗證實證法之機能，更為法解釋之基準，旨在實踐法律關係上之公平妥當，應斟酌各該事件情形衡量當事人利益，具體實現正義。<sup>90</sup>」而在操作上，法院多有認為契約解釋應通觀契約全文，斟酌訂立契約當時及過去之事實、交易上之習慣等其他一切證據資料，本於經驗法則及誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值作全盤之觀察，於文義上及論理上詳為推求，以探求當事人立約時之真意<sup>91</sup>，可見於契約解釋時，理所當然應考量誠信原則以求做出妥適之判斷。然而，觀察實務判決，卻較少見以誠信原則調整契約或具體作為當事人請求之基礎，多數與誠信原則相關的判決涉及權利失效或權利濫用<sup>92</sup>，作為自債法引入而擴及所有權利行使規範原則之誠信原則，似乎於臺灣契約法上之應用反較不常見。

實則，誠信原則作為契約法領域之指導法理，於契約解釋之領域應受到更廣泛地使用和重視，似可參考德國法中直接明示的將誠信原則與契約解釋相連結之作法。此外，根據前述，於契約領域為貫徹對當事人契約自主之保護，契約內容應可直接作為當事人請求之基礎，於此同時，應認為誠信原則作為契約法之核心概念、不應只淪為抽象概括之法理，而應使其能具體落實成為當事人得據以主張之基礎，適度擴大誠信原則之使用，以期使契約之解釋及其所促

89 王澤鑑（註18），頁590-603。

90 參最高法院104年度台上字第552號民事判決。

91 參最高法院104年度台上字第1801號民事判決、最高法院104年度台上字第1823號民事判決。

92 如最高法院104年度台上字第1083號民事判決、最高法院100年度台上字第1728號民事判決等。



成之契約履行更加符合當事人需求及最大化其經濟效率。

### 三、契約定性與類推適用

契約定性為契約解釋的第一層次，契約解釋之操作需先判定該契約究屬何種典型契約，或非典型契約<sup>93</sup>，此決定契約性質之過程即為定性，通常由當事人間權利義務分配之特性，及其契約於交易過程中著重部分為何等判斷之。而法院在審理非典型契約之案件時習於先分析該契約特徵以定性為某種典型契約或為多種典型契約之組合，將其歸類為某種成文法典已預設的典型契約類型，並類推適用該類型下之任意規定。然而於此時，所謂「類推適用」之意義究竟為何，似乎甚少被論及，因其使用甚廣，其目的及操作方式似乎應受到更嚴格及更詳盡的討論。類推適用，在法學方法上又指類比推理（analogical reasoning），在歐陸成文法體系下一般指將法律的明文規定，適用到該法律規定未直接加以規定，但其規範上的重要特徵與該規定所明文規定者相同之案型<sup>94</sup>；而在英、美判例法體系下，類比推理係運用於判決理由（legal reasoning by analogy）而非法條之適用。雖有此差異，然這僅為在不同法律體系下操作的不同，就其本質而言，此思考技術核心價值均在於「同等情況、同等處理」。民法學者王澤鑑則認為類推適用乃比附援引，係基於平等原則而將某法律規定轉移至為規定但案型相似的其他案例上，其使用上首先應探求該法律之規範目的，其次判斷不同案型是否應基於同一法律理由將原先之規定類推至其他案例適用，性質上為價值判斷的過程<sup>95</sup>。

而於比較法上，對類比推理此方法之使用有不同學說論述，如德國法學界有傳統途徑、詮釋學路徑、分析性路徑等不同取徑。傳

---

93 王澤鑑（註18），頁236。

94 參見黃茂榮，法學方法與現代民法，增訂5版，頁393（2006年）。

95 王澤鑑（註18），頁69-70。

統途徑之代表學者為德國法學方法論大家Karl Larenz，其認為類比推理之運用乃係為填補制定法之漏洞，為一種「相似性推理」。而法律詮釋學之代表人物Arthur Kaufmann則認為法律的文意與案件是時間必然存在不完全吻合的情形，此時即應利用類比推理的方式處理以將法律條文適用至具體個案中，並不以法律存在漏洞為必要，類比的應用應著重關注「事物之本質」是否具有相似性。而分析性路徑中Robert Alexy認為類比適用於案件間的比較，可包含法律解釋與漏洞填補，運用過程中除了邏輯推理，已含有價值認定之成分。總而言之，對於類比推理此法學方法，在德國學界從早期認為係屬相似性推理到後期逐漸認為亦包含一定程度的價值判斷，由此，可知類比推理並非一單純之邏輯推理過程，能將兩者做類比推理，是肇因於織成先例的理由或政策本身優越或妥當，其價值適合相干地解決相似對象的問題<sup>96</sup>。因此，在運用類推適用此手段時，必須更審慎地對待之，其雖有助於將對已知事物的認識擴展到未知事物上，但畢竟是一種或然性的推論，且含有價值判斷的內涵，不應被視為必然的真理。

總而言之，在試圖以有名契約定性無名契約並類推適用有名契約法律規定時，應持更加審慎之態度，理解類推適用此一法學方法所帶有的價值判斷性質，並非純粹只是邏輯演繹上案例是否相似的推演而已，在使用上宜考量契約背後所代表之當事人意思及其經濟安排，妥善衡量類推適用後所做之判斷是否能符合法規之立法目的，並保障當事人之契約自主等契約法之核心法理。

---

96 相關概念，作者曾著專文更詳細討論之，參見王文宇（註77），頁10-13。

## 捌、兩岸契約解釋法制的比較

### 一、臺灣法制的摘要

綜前文所述，在臺灣契約法中，立法者預設的條文效力有任意規定與強行規定之分，前者較為寬鬆，主要在補充當事人約定內容的不完備；後者則對契約自由原則嚴格限制，主要在強制當事人將一定權利義務關係納入契約中。為避免干預契約自由，二者之區別，宜嚴加認定與謹慎適用，而其區分並非易事，最終仍涉及對當事人自治與社會公平正義精神的價值判斷取捨。

契約解釋之基本原則，法條上僅民法第98條明文有「探求當事人真意」，似傾向「主觀」的契約解釋途徑，但一般學說上認為所謂真意，仍應以客觀角度，觀察當事人共同展現在外能被第三人所理解的意思為標準。近來實務見解，似較傾向認為解釋契約仍應通觀全文，並斟酌訂立契約當時及過去之事實暨交易上之習慣，依誠信原則，從契約之主要目的及經濟價值等作全盤之觀察，以推求當事人立約時之真意之看法。然而，因民法第98條內容簡陋，又判決實踐原則不具拘束力，故承前所述，法院在為契約解釋的判斷上，難免有流於恣意認定「當事人真意」之可能，解釋標準的法條明文化或具必要性。

在契約漏洞填補處理上主要有二：一為援用民法債編各論中之任意規定，二為以「假設的當事人意思」，考慮交易過程與商業習慣等來做補充契約解釋，一般認為在典型契約，應先依任意法規，再依契約的補充解釋加以填補；然在實務上，甚至是非典型契約，也習於透過分析其特徵以定性的方式，套用某一性質相近的典型契約任意規定來填補漏洞。應質疑的是，使用任意規定優先處理契約漏洞，雖可能符合立法者所預設的社會公平正義期望，但未必能實現當事人所追求的契約目的，似不夠尊重契約法的私法自治精

神，而有再檢討之必要。尤其就商事契約解釋而言，因其往往具有特殊且複雜的風險管控或分配機制，多屬於非典型契約，且多為存在漏洞的「不完整契約」，此些新型態交易之締約背景與目的非立法者制訂契約法時所能設想，如仍以任意法規作為漏洞填補之主要依據，恐造成與交易現實、本質相悖之結果，甚至可能違反契約目的，並對於交易創新造成不利影響。

## 二、中國大陸法制的簡評

《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）於1999年通過並施行，解決先前《經濟合同法》、《涉外經濟合同法》、《技術合同法》三法並立之問題。《合同法》總則部分在起草過程中借鑑了《聯合國國際貨物銷售合同公約》（United Nations Convention on Contracts of International Sales of Goods，簡稱CISG）、《國際商事合同通則》（Principles of International Commercial Contracts，簡稱PICC）之規定，在這些國際公約和國際示範法中的內容又將買賣合同的法律作為規則設計的原型進行調整，為典型的商事合同法總則；而分則部分規定有15種類型的典型合同，包括有民事合同與商事合同，其中有不少典型的商事合同，像是融資租賃合同、倉儲合同。其《合同法》在交易規則方面相當國際化，而且相當先進，例如《合同法》中設有建設工程合同的典型合同，故不致發生如臺灣工程合同類推承攬合同的弊端；還有像是《合同法》中關於基本違約事由規定的部分，拋棄德國法之履行不能理論，以統一的違約制度來救濟<sup>97</sup>，甚至較德國進步，可說中國大陸《合同法》係後發而先至。

此外，《合同法》合同終止與解除的規定相較臺灣也較合乎當事人需求及商業實務。《合同法》中的合同解除係指合同成立以

---

<sup>97</sup> 參見王利明、周友軍，與改革開放同行的民法學——中國民法學30年的回顧與展望，吉林大學社會科學學報，2009年第1期，頁88（2009年）。

後，當解除的條件具備時，因當事人一方或雙方的意思表示，使合同關係自始或僅向將來消滅之行為<sup>98</sup>，《合同法》第94條規定：「有下列情形之一的，當事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能實現合同目的；（二）在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；（三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告後在合理期限內仍未履行；（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；（五）法律規定的其他情形。」其關於解除合同的規定較妥當，有一整體性規定；相較臺灣，法定終止或意定終止則須個別適用條文。而合同之解除是否具有溯及效力，則依《合同法》第97條之規定判斷：「合同解除後，尚未履行的，終止履行；已經履行的，根據履行情況和合同性質，當事人可以要求恢復原狀、採取其他補救措施，並有權要求賠償損失。<sup>99</sup>」

在中國大陸對強行規定與任意規定之區分，為了避免法官僅依條文之措辭或用語判斷是否屬強行規定，最高人民法院有作成司法解釋，於《合同法解釋（二）》第14條：「《合同法》第52條第五項規定的『強制性規定』是指效力性強制性規定」並在最高人民法院審理案件指導意見中，強調強制性規定分為效力性強制規定與管理性強制規定，違反前者法院應判無效，而後者則依具體情形認定其效力，並要求法院應綜合考量法律法規的意旨、權衡相互衝突的權益、權益的種類、交易安全、規範對象等，以判斷強制性規定的類型，如果強制性規範規制的是合同行為本身即只要該合同行為發生即絕對地損害國家利益或者社會公共利益的人民法院應當認定合同無效。<sup>100</sup>」在《合同案件審判指導》中亦有提供類似之判斷標

98 崔建遠，合同法，5版，頁238-264（2010年）。

99 中國大陸《合同法》之解除概念亦包括臺灣民法所稱之終止，其所稱之終止為合同消滅。

100 參見最高人民法院關於當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的指導意見，法發〔2009〕40號。

準<sup>101</sup>。

《合同法》在合同解釋部分的規定亦相當先進，於《合同法》第125條規定：「當事人對合同條款的理解有爭議的，應當按照合同所使用的詞句、合同的有關條款、合同的目的、交易習慣以及誠實信用原則，確定該條款的真實意思。合同文本採用兩種以上文字訂立並約定具有同等效力的，對各文本使用的詞句推定具有相同含義。各文本使用的詞句不一致的，應當根據合同的目的予以解釋。」依此條文學者整理之合同解釋原則<sup>102</sup>：1. 以合同文義為出發點，採客觀主義為主、主觀主義為輔之原則；2. 體系解釋原則；3. 歷史解釋原則<sup>103</sup>；4. 目的解釋原則；5. 習慣解釋原則；6. 誠實信用原則。如此，則能提供法院一定程度的合同解釋基準，有助於減少恣意解釋的空間，頗值相關規定較不足的臺灣參酌。

關於合同漏洞填補之處理，先依《合同法》第61條規定：「合同生效後，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。」若仍不能確定條款內容則依法律規定，所謂法律規定，首先為分則填補漏洞之規則（例如：第139條）；其次為分則填補漏洞之具體規定（例如：第156條）；再者為總則第62條<sup>104</sup>規定<sup>105</sup>，這些皆為任意規定，可以特約排除適

101 參見最高人民法院民事審判第二庭編，合同案件審判指導，頁95-98（2014年）。

102 崔建遠（註98），頁356-357；王利明、房紹坤、王軼，合同法，4版，頁234-239（2013年）。

103 此所謂歷史解釋原則，係指解釋應斟酌簽訂合同時的事實和資料加以解釋。

104 《合同法》第62條：「當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定：

- （一）質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
- （二）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行。
- （三）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不

用<sup>106</sup>。而補充的合同解釋與任意規定之關係，有學者認為合同類型符合該任意規定之類型時優先適用任意規定，惟於以下情況優先適用補充的合同解釋：1. 合同雖具典型合同要素但具特殊性，若適用任意規定未盡符合當事人利益之情形；2. 非典型合同，適用或類推適用任意性規定違反合同目的時；3. 合同顯示當事人不願接受任意規定之適用；4. 因當事人對法定規範之錯誤想法致其效果與當事人所欲相差甚遠；5. 任意規範不符合改變的經濟關係<sup>107</sup>。

《合同法》不僅於總則第125條明定解釋合同應依交易習慣進行解釋，且在分則中大量條文都涉及根據交易習慣填補合同漏洞之規定，且將交易習慣置於任意規定前面，兩者衝突時應適用交易習慣，可推知中國大陸《合同法》相當強調以交易習慣填補合同漏洞<sup>108</sup>，特別是商事習慣，此點對於適應商業實務之運行相當有助益。然而，《合同法》有關合同解釋之相關規定雖然相對於臺灣富於彈性且尊重商業需求，但其仍有些值得改進之處。在強行規定之部分，如根據國際公約，合同時效宜交由當事人自治而非強行規定，但中國大陸《合同法》為強行規定，因此其時效規定較僵硬，可能較難以因應不同商事合同之運作情況。

此外，第125條中雖包含了多種合同解釋之原則，惟其並未詳細規定此些解釋原則之適用方式或順序，因此法官於合同解釋時仍有任意選用解釋原則的空間，仍有流於恣意之可能，其合同解釋之

---

動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。

（四）履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。

（五）履行方式不明確的，按照有利於實現合同目的的方式履行。

（六）履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。」

<sup>105</sup> 崔建遠（註98），頁372。

<sup>106</sup> 王利明、房紹坤、王軼（註102），頁232-233。

<sup>107</sup> 崔建遠（註98），頁372-373。

<sup>108</sup> 王利明、房紹坤、王軼（註102），頁233。

規定宜更加具體化與可操作化。而起所採關於合同解釋之方式仍有疑義，例如其立法究竟係採取客觀主義或主觀主義？有學者主張中國大陸主要是採取客觀解釋原則，以主觀主義原則為輔，但依第125條觀之，其同時又重視誠信原則，事實上從德國的合同解釋法則來看，主觀主義才會強調誠信原則，客觀解釋原則與誠信原則之體系並不相同，太重視客觀或文義較不易達到誠信原則和公平正義，合同解釋應有一致性，應表明其究竟其欲採取何種解釋體制。臺灣與中國大陸的合同解釋都重視誠信原則與公平正義，較傾向德國之解釋制度，但須注意同時其會犧牲可預測性，並較偏主觀解釋。

關於合同漏洞填補之問題，雖《合同法》第61條、第62條等規定為任意規定，但實務上似乎仍習於依照該規定來處理漏洞填補之問題，而非採取補充解釋合同之方式。例如於《塊狀硫磺購銷合同》此爭議中，雙方當事人沒有關於塊狀硫磺質量之約定，也沒有約定其檢驗方法、檢驗標準，此時依《合同法》第154條：「當事人對標的物的質量要求沒有約定或者約定不明確，依照本法第61條的規定仍不能確定的，適用本法第62條第一項的規定。」因無法依第61條確定，故依第62條第1項之規定：「質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。」因此買受人依工業硫磺之國家標準GB/T2449-2006進行鑑定；但出賣人主張國家標準依《中華人民共和國標準化法》分為強制性標準和推薦性標準，依該法第14條：「強制性標準，必須執行。不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷售和進口。推薦性標準，國家鼓勵企業自願採用。」該國家標準GB/T2449-2006為推薦性標準，應由企業自願採用，系爭合同並未約定適用此標準，故不應適用於系爭案件，且出賣人為外國人，並不了解中國大陸相關標準規定，只能根據合同中關於貨物品質的約定認定。有學者認為系爭案件之標的物質量必須確定，當事



人有約定時依其約定，無約定時依第154條、第61條及第62條規定，第62條規定中並未限於強制性標準，故雖為推薦性標準仍可適用，且該條將國家標準列為最優先，系爭案件應適用GB/T2449-2006標準<sup>109</sup>。本文對於系爭案件應否採取此推薦性標準有疑義，因其既為推薦性標準，並規定其為「自願」採用，應尊重合同自由及當事人自治，在該種當事人顯然沒有照國家建議在合同中自願採行之情形，假如有商業習慣，當事人沒約定應以商業習慣為優先，或以合同解釋之方式處理。

中國大陸類推適用任意規定之情形，一般不似臺灣一般氾濫，但實務上仍有出現機械式套用任意規定之案例。例如於《衡陽市錦和房地產開發有限公司與朱定仁商品房包銷合同糾紛案》<sup>110</sup>，本案之爭點在於雙方當事人所簽訂之《湘珠雅苑樓盤（住宅）銷售承包合同》（簡稱《銷售承包合同》）法律性質為何，一審將《銷售承包合同》歸類為委託代理合同；而二審認為包銷合同不同於委託合同，包銷人不僅享有銷售差價利益，同時也承擔銷售風險，包銷合同雖然兼具代理和買賣的某些特點，但不能據此認定包銷合同即為委託合同，該《銷售承包合同》就是商品房包銷合同，屬法律未明文規定之無名合同，應參照當事人的意思自治與合同目的，適用與該合同相近似的有名合同規定或總則之規定處理。本文同意二審之見解，蓋其細緻地分析包銷合同與委託合同之不同，而非如一審判決僅機械的套用委託合同之任意規定，值得肯定參考。

---

109 參見崔建遠，合同解釋與法律解釋的交織，吉林大學社會科學學報，2013年第1期，頁72-73（2013年）。

110 湖南省衡陽市中級人民法院2011年衡中法民一終字第121號。

## 玖、結語

凡法律均涉及解釋，但是每一部門法性質各異，解釋方法可能存有差異（如憲法解釋、刑法解釋），契約法博大精深，更是如此。首先，現代私法尊重契約自由，以契約法作為確保履行的憑藉，但是如何兼顧契約自由與契約法，唯賴適切解釋。其次當事人締結契約後，於履行時對契約內容的理解出現差距，此時應如何解釋契約使對立意思趨於一致，須藉助於契約解釋。再者契約可能未就某事項約定而產生漏洞，應如何處理方符合當事人利益並兼顧交易公平，亦值研究。隨著商事契約愈加複雜，加上不完整契約廣泛存在，使得契約解釋更形重要；另一方面，旨在補充當事人意思的任意規定，又與契約解釋息息相關，自然影響契約內容及解釋甚鉅。有鑑於此，我們於探討契約解釋前，允宜釐清法律解釋、契約法解釋與契約解釋三者間之關係。

論及契約解釋，首先應注意強行規定與任意規定的分際。依照歐美國家（包括德國）的契約法基本原則，強行規定如不當介入契約自由，可能阻礙市場成長與創新，增加契約的交易成本，因此強行規定的認定允宜謹慎，僅能視為契約法之例外規定。其次有些法院於解釋契約時，不時機械性地適用或類推適用任意規定來定性或解釋契約，此種「寧可誤引條文、拒絕適切解釋」的態度，使任意規定成為黏稠規定，可能違反當事人自治精神，未必妥當。最後，現代市場中許多契約具不完整性且充斥漏洞，此時如何填補契約漏洞即成為重要議題；關於此點，最近德國權威學者主張回歸假設的當事人意思，進行「補充的契約解釋」，認為或許比套用任意規定為佳，此一見解可資贊同。

欲建構完整健全之契約法，於現今商業對商業（B to B）契約越形複雜、常見之際，除健全契約解釋外，不可忽略民事與商事契約本質之不同，依其性質為適當的契約解釋，方能符合當事人之需

求。此外，契約法領域中常見之請求權基礎、誠信原則、類推適用等，早已成為兩岸法律人慣用之法律概念，然其內涵亦應隨契約法學發展重新檢視；例如誠信原則宜更廣泛地被應用，並得作為當事人請求權之基礎；再者法院於定性契約與類推適用任意規定時，宜更加審慎。本文以契約解釋為中心，參酌比較法及相關案例，呼籲正視契約特性並認真檢視契約解釋的三個步驟；唯有如此，我們方能發展更完備的契約法理論與實務。

## 參考文獻

### 1. 中文部分

- Karl Larenz著，陳愛娥譯（2008），法學方法論，臺北：五南。  
[Larenz, Karl (1991), Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlin: Springer-Verlag.]
- Thomas Raiser著，高旭軍等譯（2011），法社會學導論，5版，上海：上海人民出版社。[Raiser, Thomas (2009), Grundlagen der Rechtssoziologie, 5 Aufl., Stuttgart: UTB GmbH.]
- 王文字（2014），商事契約的解釋——模擬推理與經濟分析，中外法學，2014年第5期，頁1270-1289。
- （2014），商事契約的解釋——類比推理與經濟分析，月旦法學雜誌，236期，頁5-29。
- （2016），合同解釋三部曲——比較法觀點，中國法律評論，2016年第1期，頁60-89。
- 王利明、周友軍（2009），與改革開放同行的民法學——中國民法學30年的回顧與展望，吉林大學社會科學學報，2009年第1期，頁84-92。
- 王利明、房紹坤、王軼（2013），合同法，4版，北京：中國人民大學出版社。
- 王澤鑑（2001），民法總則，增訂版，臺北：自版。
- （2006），債法原理（一），臺北：自版。
- （2010），法律思維與民法實例——請求權基礎理論體系，2版，臺北：自版。
- 史尚寬（1986），債法各論，臺北：自版。
- 向明恩（2015），加盟契約在臺灣司法判決帶來之民事爭議——從加盟契約之目的出發，月旦法學雜誌，238期，頁131-155。

- 崔建遠（2010），*合同法*，5版，北京：法律出版社。
- （2013），*合同解釋與法律解釋的交織*，*吉林大學社會科學學報*，2013年第1期，頁70-79。
- 陳自強（2004），*契約之內容與消滅*，臺北：學林。
- （2005），*民商合一與民商分立*，*月旦民商法雜誌*，10期，頁71-101。
- 黃立（2002），*民法債編總論*，臺北：自版。
- 黃茂榮（1982），*民法總則*，增訂版，臺北：自版。
- （2006），*法學方法與現代民法*，增訂5版，臺北：國立臺灣大學法學叢書編輯委員會。
- （2006），*債法各論（一）*，增訂版，臺北：植根。
- 最高人民法院民事審判第二庭編（2014），*合同案件審判指導*，北京：法律出版社。
- 劉春堂（2011），*民法債編通則（一）——契約法總論*，增訂版，臺北：三民書局。
- 韓世遠（2015），*民事法律行為解釋的立法問題*，收於：*民法的解釋論與立法論*，北京：法律出版社。

## 2. 外文部分

- Ayres, Ian. 2012. Regulating Opt-Out: An Economic Theory of Altering Rules. *Yale Law Journal* 121:2032-2116.
- Bork, Reinhard (2011), *Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs*, 3. Aufl., München: C. H. Beck.
- Canaris, Claus-Wilhelm, and Hans Christoph Grigoleit. 2010. Interpretation of Contracts. Available at <http://ssrn.com/abstract=1537169>.
- Grigoleit, Hans Christoph. 2011. Mandatory Law: Fundamental Principles. Available at <http://ssrn.com/abstract=1950670>.
- Katz, Avery Wiener. 1999. An Economic Analysis of the Guaranty

- Contract. *The University of Chicago Law Review* 66:47-116.
- Kötz, Hein D. (2013), Dispositives Recht und ergänzende Vertragsauslegung, JuS, S. 289-296.
- McMeel, Gerard, and Hans Christoph Grigoleit. 2013. Interpretation of Contracts – Prospective European Regulation from the English and German Point of View. Available at <https://ssrn.com/abstract=2221051>.
- Posner, Eric A. 2005. There Are No Penalty Default Rules in Contract Law. University of Chicago Coase-Sandor Institute for Law & Economics Research Paper Series, Olin Working Paper No. 237. Available at <http://ssrn.com/abstract=690403>.
- Posner, Richard A. 2004. The Law and Economics of Contract Interpretation. *Texas Law Review* 83:1581-1614.
- Rubin, Paul H. 1978. The Theory of the Firm and the Structure of the Franchise Contract. *The Journal of Law & Economics* 21:223-233.
- Schwartz, Alan, and Robert E. Scott. 2003. Contract Theory and the Limits of Contract Law. *The Yale Law Journal* 113:541-619.
- Scott, Robert E. 2006. The Law and Economics of Incomplete Contracts. *Annual Review of Law and Social Science* 2:279-297.
- Scott, Robert E., and George G. Triantis. 2010. *Foundations of Commercial Law*. Durham, NC: Carolina Academic Press.

## Contract Interpretation and Default Rules: A Comparative and Case Study

*Wen-Yeu Wang\**

### **Abstract**

Contract interpretation is an omnipresent phenomenon of contract law. Contracts often contain gaps, either because the parties did not consider a question at all or because they deliberately abstained from dealing with it. In that case, the questions for which no provisions were made need to be solved by applying other methods. In this regard, all Continental Civil Law systems contain supplemental rules or default rules to complete contractual arrangements. However, default rules can only achieve their goals if they responds to the typical interests that can be attributed to the parties of the particular types of contract. Ultimately, interpretation of contracts must comply with the principle of freedom of contract. Against this background, this article conducts a comparative and case study on the relationship between contract interpretation and default rules. It has found that, in some cases, Taiwanese courts have either hastily characterized the contract in question as a typical contract without inquiring into its nature or purpose, or rigidly employed a method of analogy to incorporate the corresponding default provisions into the contract in question. To remedy these deficiencies, this article concludes by proposing a three-step process in interpreting contracts. First, the court should distinguish between mandatory rules and default rules. Second, the court should clarify the differences between contract interpretation and default rules. Third, the court should consider alternative method of filling contractual gaps, rather than mechanically or rigidly applying default rules.

---

\* Professor, College of Law, National Taiwan University.

KEYWORDS: contract interpretation, default rules, mandatory rules, comparative study, freedom of contract, contractual gaps, method of analogy.